

重新檢視死刑的應報意義*

謝煜偉**

摘 要

本論文先簡明指出臺灣死刑存廢爭議的現況，相較於嚇阻論屢屢受到實證上的質疑，近年來應報刑論重新受到重視，並多援引作為支持死刑的根據。然而，應報概念的不清晰往往使得議論失焦。本論文先釐清應報概念的內涵，並檢討諸種應報理論與死刑正當性基礎之間的關係，並從社會契約論的角度指出應報論在市民刑法底下最根本的問題點。接下來，從深層的社會意義分析死刑，並探求「得以科處死刑之責任」的真義。最後在現行法仍存有死刑的前提下，提出修正的社會應報觀點，主張社會整體需負起終極的犯罪處理責任，犯罪者之生命一旦被國家有意識地剝奪，這個終極的犯罪處理責任即無法完遂。

關鍵詞：應報、社會契約、自然狀態、敵人刑法、責任。

* 投稿日：2013年2月22日；接受刊登日：2013年6月25日。〔責任校對：鄭育翔、洪瑋辰〕。

筆者衷心感謝兩位匿名審查人之指正，使本文更具可讀性，惟文責仍由筆者自負。本文初稿曾發表於2012年10月19日，中央研究院法律學研究所主辦之「2012法律思想與社會變遷——生命與正義」學術研討會，非常感謝主持人劉幸義教授、評論人許恒達副教授、中研院法律所張永健副研究員以及許家馨助研究員之寶貴意見。另，本文為筆者執行國科會計畫「死刑量刑基準之研究：以2002年到2012年之死刑確定判決分析為中心」（NSC 101-2410-H-002-219-）之部分研究成果。

** 國立臺灣大學法律學院助理教授。

穩定網址：<http://publication.iias.sinica.edu.tw/30701141.pdf>。



目 次

壹、死刑存廢爭議的膠著現狀	參、作為社會現象的死刑與責任概念
一、議論現況	一、Kramer 的翦除論
二、問題所在	二、得以科處死刑的責任
貳、應報刑與刑罰理論	肆、翻轉思維方向的嘗試：修正的社會應報觀
一、多樣的應報概念：復仇、報復與應報之區別	伍、結語
二、罪刑均衡的目的及其內涵：比例性、相稱性、同害報復法則	
三、應報刑論的多種樣貌	
四、社會契約、應報與刑罰	
五、小結	

壹、死刑存廢爭議的膠著現狀

一、議論現況

近代的死刑制度可回溯自11、12世紀的歐洲，當時伴隨著政治權力的擴張以及犯罪概念與處罰範圍的擴大，宗教上的贖罪金之收受逐漸失其意義，乃藉由刑罰以圖防止犯罪，而由於政治權力仍然相對貧弱，為了要維持治安，對應大量（現有及潛在的）犯罪者，死刑成為刑罰的中心，而死刑的執行方法也模仿宗教上的獻祭儀式，而有眾多形態¹。

死刑存廢之爭議，除法律外還涉及政治、社會道德、宗教等因

¹ 參見吉岡一男，刑事學，新版，頁174（1996年）；瀧川幸辰，刑法史の斷層面，頁68以下（1963年）。

素，一直是各界爭論不休的議題。學術與實務各界有關死刑存廢與否之探討眾多，但在2010年當時的法務部長王清峰因拒絕執行死刑而下臺後，社會輿論幾乎一面倒傾向維持死刑制度存續，並希望重啟死刑執行程序²。同年3月上任的法務部長曾勇夫也在上任一個多月後即批准四張死刑令。臺灣目前的死刑相關議論，可以說多數集中在「應否廢除死刑」以及「應否執行死刑」這兩個層面。

探討死刑存廢，常見有以下幾種理論路徑。首先，從死刑效益及成本的觀點，探討死刑的嚇阻力以及負面效果。包括誤判、死刑替代方案，以及是否要停止執行死刑等的討論等。主張廢除死刑一方認為，死刑執行具有不可回復性，誤判與冤案再怎麼避免也不可能消除；死刑在實證上不具有嚇阻效果，死刑與殺人罪犯罪率之間並沒有明顯的相關性³；況且維持死刑制度需耗費龐大的預算，甚

2 有關近年臺灣死刑存廢爭議的整理及評論，見黃榮堅，2010年刑事法發展回顧：慾望年代？慾望刑法？，臺大法學論叢，40卷特刊，頁1795以下、頁1801（2011年）；陳淑貞，廢除死刑重大議題解析，全國律師，15卷8期，頁39-51（2011年）；王皇玉，死刑在臺灣，台灣法學雜誌，170期，頁45-74（2011年）；劉幸義，死刑存廢爭議——反思亂世用重典——The Controversy over the Death Penalty Reflection on Severe Penalty in Times of Disorder，台灣法學雜誌，169期，頁90-92（2011年）；李茂生，死刑存廢論再考——分析反對廢死者的深層心理，台灣法學雜誌，169期，頁71-89（2011年）；王兆鵬，台灣死刑實證研究，月旦法學雜誌，183期，頁105-130（2010年）。而在2010年爭議之前的議論狀況，參見臺灣廢除死刑推動聯盟編，死刑存廢的新思維——社會安全、獄政革新、被害人保護，頁217以下（2009年）。

3 國外多有文獻在探討死刑與嚇阻犯罪的關聯性，由於臺灣欠缺全面廢死的經驗，並沒有更明確的實證資料可供證明兩者究竟有無關聯，但由於2006年以後殺人案件的統計數字有明顯下降趨勢，而此期間並未執行死刑，因此有學者便以此說明死刑其實並不具備嚇阻犯罪（殺人罪）之效果。參見王皇玉（註2），頁71；黃榮堅（註2），頁1795以下。相關數據，參見法務部保護司編，中華民國100年犯罪狀況及其分析，頁50（表2-2-8：地方法院檢察署起訴之暴力犯罪人數）（2012年）。當然，反對者可以質疑：在技術上停止執行死刑未必代表死刑的一般威嚇作用消失，只要死罪的立法仍舊存在，在社會心理上的威嚇效果並非不可想像。但無論如何，死刑能否發揮實際的威嚇作用一事並無有效的資料得以證實。其實更極端一點說，刑罰的嚇阻作用（或一般預防作用）其實也建立在共同想像出來的基礎之上，如果真要從威嚇或抑止人犯罪角度思考整個刑罰制度，那麼或許得出的答案可能是非常消極的。

至比終身刑過之而無不及，一個既耗費龐大成本又沒有明顯效益的制度，沒有繼續存在的必要。而支持死刑存置者卻一一反駁，認為誤判與冤案問題是整體刑事制度的問題，自由被剝奪也同樣無法回復；實證上也可找到具有嚇阻力量的研究，重點是死刑具有對社會大眾一般性的威嚇效果以及秩序穩定作用；死刑的替代方案同樣耗費社會成本等等。不過，功效主義的立論方式似乎都沒有辦法成為鼓動廢死或反廢死心理的主要力量。況且，效益與正當性並不能當然畫上等號，犯罪預防固然可能是刑罰制度的正當性基礎，死刑亦有可能是有效率嚇阻（一部分）犯罪（者）的手段，但並不能就因此說死刑具有正當性。死刑的正當性基礎勢必要從其他角度來論述。

另有從宗教上的倫理誡命來論證「死刑之不可能」。論者認為我們需堅持「人不可殺人」這項第一義的倫理誡命，這是無從考慮選項的絕對誡命，因此廢除死刑不是價值選擇，而是遵守倫理誡命。而死刑制度意味著殺人行為的常態化，意味著國家以正義之名踰越第一倫理。而倫理的孿生概念是贖罪，因此當社會或國家以正義之名破壞第一倫理誡命的時候，能做的最大倫理實踐是在每次執行死刑之後全體社會懺悔自己的作為，為自己破壞第一倫理而贖罪⁴。姑且不論在不同宗教信仰之下，各人所信服的倫理誡命內容是否一致，至少，論者清楚地從倫理觀點討論死刑不應存在。

但相反的，亦有刑法學者從自我負責倫理之角度表明死刑的必要性。氏認為「死刑，只為了一個理由：重大犯罪人必須在倫理上終極的自我承擔。死刑同時也證實了人的自主性：自己思索、自己作主、自己負責、走自己的死路。⁵」姑且不談這種將刑罰的苦痛本質、以及國家權力介入的本質抽離的問題性，至少，這種說法訴

4 陳正國，死刑之不可能：一個簡單的倫理學觀點，思想，18期，頁267-277（2011年）。

5 林東茂，刑法綜覽，6版，頁25-26（2009年）。

諸了人需為自己的行為負終極責任的應報觀點。這種說法某程度也對「死刑違反人性尊嚴」等廢死主張提出反論，因為按照康德（Immanuel Kant）的說法，死刑是法不可或缺的基礎，而死刑不但沒有違反人性尊嚴，透過處刑，死刑犯的人性尊嚴才得以獲得。至此也可以理解康德從人性尊嚴的立論基礎延伸出絕對應報的觀點。生命至上的倫理觀、人性尊嚴的論理，固然已經逼近死刑正當性論爭的核心，但所謂生命至上、人性尊嚴概念本身仍存有不同解釋的餘地。因此議論仍然陷入泥淖中。更重要的是，由後述可知，強調人性尊嚴的立論方式反而潛藏著以死刑排除那些不配享有人性尊嚴之「非人」的危險性。

廢死論者亦主張「死刑是殘酷的刑罰」。不過探討死刑是否殘酷，必須要釐清兩個不同的問題，亦即，究竟是討論執行手段具殘酷性，抑或討論剝奪生命本身（無論用哪一種無痛或所謂人道的執行方式皆然）就是殘酷的？如果是後者，其實與前段主張人性尊嚴或生命至上的觀點是相同的命題。而如果是前者，可以透過但這個論述也可以透過所謂人道的（無痛、不流血、給予臨終前適度尊重的）執行方式加以反駁。也因為死刑執行可以用麻醉去除臨死的痛苦等死刑執行技術的革新，導致這種「死刑是殘酷刑罰」的論證方式失效⁶。因此，縱使在日本的廢死運動仍繼續訴求死刑執行方式（絞首刑）過於殘酷而違憲，但也不是一項單獨具有效果的論述，仍然需要與生命不可剝奪的問題層面一併思考⁷。

死刑廢止論另一項常被批判的主張是所謂的國際潮流論。這個主張在經過某種刻意誤解、渲染與放大之後變成是反對者調侃廢死

6 參見小坂井敏晶，責任という虚構，頁86-88（2008年）。

7 參見土本武司，絞首刑の法的根拠と残虐性，判例時報，2143号，頁3-8（2012年）；山田隆司，絞首刑と「残虐な刑罰」，法学セミナー，57卷1号，頁52-53（2012年）；菊田幸一，アメリカにおける死刑に関する司法判断と日本国憲法——いわゆる「残虐な刑罰」を中心として，法律論叢，61卷4・5号，頁155-159（1989年）。

運動的主因。一方面，訴諸國際社會的廢死趨勢，只會顯示出廢死論述的無奈，必須喚起大眾追隨國際潮流的念頭以求廢除死刑。不過，正因為臺灣人已習慣於自己身為國際孤兒的地位，不但可以拿出仍保有死刑的美國及日本當做擋箭牌，甚至順勢展現出抗拒不合理國際壓力的氣魄。但實際上，當中華民國政府批准並將公民與政治權利國際公約（International Covenant on Civil and Political Rights，簡稱ICCPR）內國法化之後，無法自外於有關ICCPR條文之解釋與適用：ICCPR第6條第2項所謂「情節最嚴重之罪」應如何在現行中華民國的刑事法體系下解釋⁸？以及如何回應同條第6項「締約國不得援引本條而延緩或阻止死刑之廢除」此種全面廢除死刑的終極目標？這些問題已經不是「是否要跟隨國際潮流」這麼單純。更現實的狀況是，當本欲追訴或處罰的犯罪者逃亡至國外，該國有「死刑犯不引渡條款」或為ICCPR第2號任擇議定書（optional protocol）之締約國，則極有可能因為臺灣尚未廢除死刑或無法向該國提出「不執行死刑之確切保證」，而使得我國無法引渡犯罪者回臺受審或受處罰⁹，這當然是本國刑事審判秩序的妨害，而必須要更嚴肅來

8 按照聯合國人權委員會對ICCPR第6條之官方評註，任何死刑之犯罪條件均應嚴格限縮解釋，使其僅得適用於最極端之情形。而依照目前經委員會與通說默視同意符合判處死刑要件的僅有故意殺人一項，其餘如無直接被害人犯罪、經濟犯罪、毒品犯罪或宗教禁忌有關之犯罪，都不應被判處死刑。黃居正，扎基告加拿大案：死刑與國際法，台灣法學雜誌，206期，頁27（2012年）。嚴格而論，「情節最嚴重」解釋上應該要分成死刑立法以及死刑量刑兩個層次，固然在立法層面至少應先廢除殺人及殺人結合犯以外之罪的死刑，在殺人等罪的量刑因素判斷中，也應該去思考現行裁判就死刑的量刑基準是否合乎情節最嚴重之要求。

另請參見近期令人矚目的最高法院102年度台上字第170號刑事判決（吳○誠殺人案），判決中已明白宣示ICCPR內國法化之後，我國有關於死刑量刑之決定，包括程序及實體都必須要符合該公約第6條，適用之際尚需參照其立法意旨及兩公約人權事務委員會之解釋。從兩公約等國際人權法角度討論現行死刑制度問題者，參見張文貞，國際人權法與內國憲法的匯流：臺灣施行兩大人權公約之後，收於：社團法人臺灣法學會編，臺灣法學新課題（八），頁1-26（2010年）。

9 黃居正（註8），頁23以下。有關死刑與國際人權法的問題點，參見高山佳奈子，死刑制度をめぐる問題，法律時報，1046号，頁36以下（2012年）。

看待相關問題。

以上簡單敘述死刑存廢論爭雙方的主要論點，以及對論點的回應¹⁰。當然，本文主旨並非直接處理死刑存廢論爭，而是要指出：死刑存廢爭議在一來一往之間陷入膠著狀態，但，這種膠著狀態的根本原因並不是來自於死刑存置論與廢止論之間的對立，毋寧說死刑論爭本身的不確定性導致了齟齬，而只要陷入膠著狀態，就是存置論者的勝利。因為死刑制度作為一既成事實，廢死論必須要費力舉出死刑的缺失、弊病以及制度的問題，反觀存置論者甚至無需積極證立死刑的正當性，只需要對廢死主張一一提出反論即可。不過，死刑之所以存在或許只是基於對死刑習以為常，但這並不代表習以為常的制度就是正當的¹¹。

二、問題所在

在這一兩年廢死議題白熱化後，死刑是否能有效率遏止重大犯罪一事陷入各說各話的局面，死刑的預防（嚇阻）功能不再是輿論支持死刑的唯一訴求¹²，相反的，開始有聲音認為死刑根本的意義不在於嚇阻，而是在應報。此處所謂「重新重視死刑的應報意義」的說法，嚴格來講未必清楚分辨復仇、報復與應報之間的差異，在一般人的觀念認為，所謂的應報概指「殺人償命」、「以死謝罪」的

10 有關日本的死刑存廢論爭主張，可見：辻本義男，死刑論争へのアプローチ，ホセ・ヨンパルト（José Llompart）、三島淑臣編，法の理論6，頁165-186（1985年）；間柴泰治，死刑をめぐる論点——死刑存置論と死刑廃止論，調査と情報，651号，頁1-11（2009年）；三原憲三，死刑廃止の研究，6版，頁235以下（2010年）。

11 柯耀程，死刑制度對犯罪被害人的迷思，收於：刑法問題評釋，頁328-329（2004年）。

12 曾有學者以死刑預防效果化約為「殺人以救人」，以迫使廢死論者反省生命價值至上的命題。參見：陳嘉銘，積極殺一人或消極殺五人，中國時報，2010年3月16日A14版。但即便是反廢死論者也未必同意這種論述方式。更重要的是，如果要從實證研究尋求答案，反而會因為實證上沒有明確的相關性而導致死刑制度陷入目的手段關連性不明確的違憲疑慮。

庶民正義觀¹³。這種強調「殺人償命」等對價償還的庶民正義觀，以及近年來社會情境的變遷（變得更暴戾、更噬血），或許可以說是近年讓廢死運動嚴重受挫的重要理由。

按照現行法，並不是唯有生命法益受侵害的犯罪類型，才可以判處死刑，反之，客觀上生命法益的侵害，也並不當然導出應科處死刑的結論，仍然有量刑上審酌刑度的空間¹⁴。按照我國死刑的實證研究結果，在解嚴之後，我國量處死刑之案件大多為殺人罪、強盜殺人罪、強制性交而殺人罪、擄人勒贖殺人罪等有侵害生命法益之犯罪。也有少數因運輸、販賣毒品而被量處死刑之案例，只不過這些未侵害生命法益的死刑判決都是發生在2002年以前，在此之後便不曾有未侵害生命法益而遭死刑判決之例¹⁵。而這些死刑定讞的被告所犯罪名之法定刑，除普通殺人罪是「死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑」之外，其他如強盜殺人、擄人勒贖殺人、強制性交殺被害人、殺害直系血親尊親屬等罪之法定刑皆為「死刑或無期徒刑」。從罪質來看，單純的殺人罪會被判處死刑，勢必有其他加重量刑因素的考量；如生命法益侵害的個數、犯罪手段以及犯罪後態度，皆是影響到殺人罪是否科處死刑的重要指標之一。

其次，從量刑事由而言，一般可分成「與犯罪行為有關之量刑因素（客觀量刑因素）」與「與行為人有關之量刑因素（主觀量刑因素）」兩大類。各個量刑因素有可能各自產生有利於行為人（減輕效果）或不利於行為人（加重效果）兩種形態。死刑判決的出

13 關於庶民正義觀的概念使用及說明，參見謝世民，為廢除死刑提供一種有限的證成，思想，17期，頁209-220（2011年）。

14 在一般的、抽象的層次（立法）肯認有法定刑為死刑的犯罪，在個別的具體的事案當中，是否需要量處死刑又是截然不同的問題，詳後述。關於死刑的量刑基準，請參見石木欽，臺灣刑事案件量處死刑之原則與趨勢（上），司法周刊，1532期，頁2-3（2011年）；石木欽，臺灣刑事案件量處死刑之原則與趨勢（下），司法周刊，1533期，頁3（2011年）。

15 王兆鵬（註2），頁121。

現，反映出法院對各個量刑因素的評價程度，例如，犯罪手段凶殘程度、犯罪後態度（未與被害者家屬和解、審理時狡辯），這些死刑量刑因素並不能當然與「應報」有關。此際，死刑或無期徒刑量刑差異的實證研究便有相當程度的重要性。然而，兩者之間往往留有極高程度的灰色地帶。

特別是幾乎所有的死刑確定案件都是在審級之間遊走數次後才定讞，而除了歷審皆判處死刑的案件外，各個量刑事由的評價，以及量刑因子的重要性在判決理由當中都是不穩定而模糊的。由於充斥了許多並不與犯罪輕重直接相關的判斷，以致於即使犯罪事實不變，也可能因為其他量刑事由的審酌而影響了死刑的出現。如果相類的事件（例如被殺害者人數相同），可能得出死刑也可能得出無期徒刑的結果，那麼「情節最重大之犯罪」與「死刑」之間的對應關係，也不能完全符合「應報」的想法，而帶有其的考量在內，換言之，死刑在司法審判的層次，也不能簡單用「殺人償命」就能夠交代清楚死刑的機能。例如判決常以「無教化可能性」、「有再犯之虞」、「有與社會永久隔絕之必要」等作為判決死刑之積極理由，從這點來看，與其說死刑判決貫徹了罪罰相當之應報觀，不如說是以從無矯治可能性連結到隔離無害化的論述方式作出死刑之決定。

是以，無論在立法的層次抑或司法審判的層次，都不全然是死亡對死亡的對價關係。死罪與死刑之間的關係並不能在真空狀態下討論，必須要在更細膩的事實基礎上，討論死刑的各項意義。因此，無論是「殺人償命天經地義」或「生命權神聖不可剝奪」，其實某程度上都是一種真空式的論述。不但沒有助於問題的釐清，反而淪於各自表述道德價值的無限迴圈。

不過，我們要深思的是：儘管實際上立法中的死刑與審判中的死刑，都不能夠徹底符合「殺人償命、天經地義」的正義觀，也未必能填補被害者（遺族）的憤怒，為什麼在死刑存置論者仍繼續以

這種生命對價與被害（復仇）的觀點去論證死刑制度的正當性及必要性？可以說，對價償命的邏輯與被害復仇的邏輯都覆蓋在「應報」這個大方巾之下，強調死刑的應報意義看似成為反廢死論最有說服力的依據。然而，究竟這種「殺人償命」的正義觀，與刑罰論中的「應報」可否畫上等號？死刑究竟發揮什麼樣的應報效果？以及，這種加害者以死向被害家屬償罪的正義觀背後所代表的社會意義為何？這些問題似乎並沒有在死刑存廢論爭中獲得清楚而細膩的檢討。

另一方面，我們也可以認真追問，為何國家可剝奪人民生命？有無可能從近代政治哲學的源頭找尋死刑的正當性基礎？筆者試圖從死刑與國家刑罰權之間的關係，反思死刑¹⁶。刑罰作為現代國家權力行使最直接而強烈的手段，有其特定的目的，而死刑既然被視為是「刑罰」的一部分，理論上也必須符合這些刑罰目的的檢驗。特別是近來刑法界有所謂康德、黑格爾（G.W.F. Hegel）刑罰哲學的復興，眾所周知，康德與黑格爾都是支持死刑的啟蒙哲學家，而復興後的新刑罰理論能否順利解釋死刑的存在，自然有檢討之必要。相對於康德與黑格爾刑罰哲學的復興，日本學者一ノ瀬正樹則從洛克（John Locke）理論出發提出「死刑不可能論」，認為「剝奪生命」已超出近代刑罰概念之外，死刑不具有（嚴格意義的）刑罰適格。眾所周知，洛克本身支持死刑，但透過一ノ瀬的分析能夠對洛克的刑罰論有一番新的詮釋。

談論死刑的應報意義，除了從哲學的角度來分析外，不能忽視死刑作為一種社會現象所展現的諸種面貌。死刑除了「犯罪預防」之外，在社會中還扮演了什麼樣的角色？其深層的意義為何？同時，在死刑仍存續的現實狀況下，法體系內部如公正應報以及責任

16 就此主題，現有的詳細論述，可見蕭高彥，死刑存廢：政治思想與哲學的省思，思想，17期，頁123-141（2011年）。

等概念又是如何被建構出來的？本文希望從「法外」的社會現象角度來看死刑與責任概念之間的關係，最後提出己見。

貳、應報刑與刑罰理論

一、多樣的應報概念：復仇、報復與應報之區別

討論應報刑論的意涵，必須要先認清應報概念的多樣性。現今所謂的「應報」其實已經被純化為對罪行相對應的制裁。不過，這並不是這個概念的全部。常被提出來比較的是復仇、報復與應報之間的關係¹⁷。

復仇是被害者一方對加害者一方的反擊，由於這種反擊出自於心理上的復仇心態，是基於被害者一方個人自然發生的情緒性反應，也可能是被害集團的歇斯底里現象，這種復仇式的攻擊在社會制度已健全的社會仍舊可見（如群眾追打被告）。復仇的特徵有二，一是**攻擊主體之限定**。復仇必須限定在被害者或與被害者具有密切人際關係之個人或團體（被害遺族）。第二，復仇與其說是針對先前加害內容的回報、報復，不如說是以被害為契機的攻擊，因此，**被害與反擊間的均衡並不是復仇的核心要素**，其次，由於被害只是作為加害的契機，而無內在的節制原理，因此會形成**私人血仇的連鎖**。總之，從過去的刑罰史觀察，雖然應報刑可以連結至復仇之概念，但近代以前的贖罪金等概念也意味著以制度解決侵害與抗爭，從私人轉向公眾或社會的制裁手段，以避免血仇的連鎖¹⁸。

¹⁷ 引自吉岡一男，*應報刑と謙抑主義*，京都大学法学部百周年記念論文集刊行委員会編，京都大学法学部創立百周年記念論文集，第2卷，頁505-507（1999年）。

¹⁸ 吉岡一男（註17），頁506。

相對於具連鎖性卻不具均衡性的復仇，社群發展到一定程度之後，會產生新型態的反擊機制。在此可稱這種機制為「報復」。報復機制跟復仇最大的不同在於施以反擊的主體開始擴張；報復的行為主體並不以被害者一方為限，也可包括主權者以天罰之名所為之制裁。可以說從社會心理的面向而言，報復並不是單純基於復仇感情下的反擊，而是冷靜且有意識的思考報復手段。這種報復機制仍然存在著被害者對加害方的回擊色彩，但又同時緩和了一定的社群控制機能在內，因此出現抑制復仇情緒與劃定處罰限度的特性，所謂同害報復（retaliation）即為典型。

而更中性的概念是善有善報、惡有惡報的報應（desert）或應報（retribution），其特色是注重加害者一方的原因性以及責任（因果報應），而非對加害者的報復或復仇。因此，對於犯罪之惡乃基於均衡與正義的感覺施以刑罰。如此一來，罪刑均衡成為公正報應（just desert）的本質性要素，而重點放在責任的追究。應報情感轉變成為要求賦予加害者與其責任相應的惡害。而縱使此種應報情感也來自於個人的復仇心理或公眾的憤怒，但其重點是在於透過贖罪等方式要求原因的解明以求事件落幕。

可以說一般人所謂的應報就在於洩憤所帶來心情上的愉快，但是對社會發展而言，報復心態對整體社會利益最後的作用卻會帶來血仇連鎖等惡性循環¹⁹。因此雖然所謂的「應報情感」帶有復仇心、公眾激憤、要求責任追索及事件解明等複合情緒。但在著重責任與罪刑均衡的脈絡下，肯認刑罰具有應報性格一事，重點就會放在要求相應於犯罪程度的惡害賦予，以抑制復仇與報復心態的面向。

綜上所述，現今的應報思想有三個先決條件：（一）國家有刑

¹⁹ 黃榮堅，基礎刑法學（上），4版，頁17（2012年）。

罰權，對犯罪賦予相對應的惡害。(二)罪責輕重具有可分性。(三)罪責的程度需與刑罰的高低度相當²⁰。簡言之，作為公正應報的刑罰，在於惡害賦予以及罪刑均衡。就此，罪刑均衡的概念需更進一步來檢視。

二、罪刑均衡的目的及其內涵：比例性、相稱性、同害報復法則

日本前期舊派的代表性人物瀧川幸辰對罪刑均衡作出了一個具有時代特色的解釋。其認為，均衡的理念起源自商品交換之社會形態，在現今的資本生產支配的社會中，均衡的交換型態甚為一般，而維持罪刑之均衡關係甚為明瞭²¹。不過這種說法並不為多數見解所採。畢竟刑罰的苦痛賦予並不代表換取被害的對價，這種商品交換的概念在不但在傳統私人復仇的制度中無法適用，在刑罰權收歸國家專有的制度裡，被害者一方也無適用的餘地。比較無爭議的是罪刑均衡在現代法治國之中，具有消極的限制國家刑罰權行使的目的，亦即，行為責任乃刑罰發動的必要條件，卻非充分條件，而行為責任則是刑罰的上限，刑罰必須在責任程度之限度內行使。換言之，罪刑均衡一方面是應報概念的內涵，同時也是責任原則的核心原理²²。

與罪刑均衡原則有關的概念是犯罪輕重與刑罰高低的比例性（proportionality），以及犯罪與處罰（惡害賦予）程度的相稱關係（commensurateness），以及同害報復法則（*lex talionis*）。首先，就比例性而言，係指犯罪輕重之序列需與處罰輕重之序列相應，例如比竊盜還嚴重的強盜罪，其刑罰在一般的情況下要比竊盜的刑度更

20 林山田，刑法通論（下），10版，頁417（2008年）。另請參照蘇俊雄，刑法總論I，2版，頁141（1998年）之說明。

21 瀧川幸辰，刑法講話，頁4以下（1951年）。

22 林山田（註20），頁416；內藤謙，刑法講義總論（上），頁127以下（1983年）。

重，而殺人又要比強盜處罰更重。換言之，合比例性注重的是犯罪類型內部的輕重排序必須對應到刑罰高低的序列，因此一個罪質相對較輕的犯罪就不能適用較重的刑罰。這種罪與刑的內部均衡要求，成為罪刑均衡原理的最重要概念。但是合比例性只能夠檢討罪與罪之間刑罰是否輕重失衡，卻對刑罰的絕對值是否失衡一事無能為力。

相稱性強調的不是輕重序列的問題，而是刑罰量是否與犯罪程度相稱的問題，亦即犯罪對價性的問題。例如竊盜是否值得用五年以下有期徒刑來處罰等等。因此，一個整體皆重刑化的刑法典，或許可以符合合比例性的要求，卻不能通過相稱性的檢驗。不過，理論上相稱性的想法頂多只能處理例如竊盜可處終身刑那種極端失衡的情況，在現今以自由刑及罰金刑為主要刑種的法治國家中，我們很難去運用相稱性的概念批判法定刑普遍過重或過輕。換言之，在經過自由（自由刑）或金錢的換價程序之後，究竟犯罪行為的對價要訂多少，不同國家有其各自相異的背景因素需要考量。是以，這種絕對的罪刑均衡基準點，毋寧說是難以特定的²³。然而，這種絕對的均衡基準點其實可以溯及到同害報復法則。

同害報復法則其實就是俗稱的「以牙還牙、以眼還眼」，可以追溯至漢摩拉比法典以及舊約聖經²⁴。這種必罰主義的刑罰思想，

23 內藤謙（註22），頁126。

24 聖經上死刑的律法載於〈出埃及記〉、〈利未記〉、〈民數記〉以及〈申命記〉。如〈出埃及記〉21：12「打人以致打死的，必要把他治死」、21：22-25「人若彼此爭鬥，傷害有孕的婦人，甚至墮胎，隨後卻無別害，那傷害她的，總要按婦人的丈夫所要的，照審判官所斷的，受罰。若有別害，就要以命償命，以眼還眼，以牙還牙，以手還手，以腳還腳，以烙還烙，以打還打」。但聖經裡的死刑律法並不只限於以牙還牙的同害報復思想，大多數為悖逆上帝之罪，另還有觸犯特定人格、職份關係之罪，如不孝敬父母、背叛婚姻、誘拐人以撕裂他人家庭關係之罪等。而除了治死、打死、或用火燒死之外，還有一種「翦除」之處罰，主要記載在〈利未記〉。翦除不是死刑，而是將邪惡（evil）從你（們）（身上）排除出去的制裁手段，而翦除（purge）原本即有洗滌（罪惡）與淨化之意。翦除的實質效果相當於死刑，從現代眼光來看，這種翦除之處罰與以隔

在近代則可以康德的主張作為代表（絕對應報刑論）。這可以說是讓「罪」與「罰」直接達成完全相稱的要求，過去致生多少惡害，就需接受同等程度、同等內容的制裁。有認為這種以相同傷害回擊作為處罰的方式只是復仇的延伸，是赤裸裸的報復手段，但這可能只是對同害報復概念的理解的誤解。同害報復法則其實蘊含了兩個重點，一是處罰不能踰越犯罪所損傷之程度，意味著對於私人血仇或公眾報復的限制，而帶有節制處罰的意義；二是指出了罪刑對應上的絕對標準，其提供了一個判斷是否達到罪刑均衡的有效尺度，無須經過自由或金錢的換價程序。

以現代刑法的眼光來看，同害報復法則沒有繼續沿用的必要。除了剝奪行動自由罪以及財產犯罪的處罰有可能符合同害報復的外衣（實質上當然並非出於同害報復思想），以自由刑及罰金刑為主的現代刑法典當中，都脫離了這種過於原始的報復方法。唯有當以「生命」換取「生命」的情況，同害報復法則卻又冒出頭來，成為支撐死刑應報意義的最重要支柱。固然，「殺人償命」的同害報復思想只是表達了使用刑罰的行動態度，表達了處罰不能踰越當初傷害他人的程度，但是並沒有說明為何要使用刑罰²⁵。很顯然，若要問有無其他刑罰可作為死刑的替代方案，從同害報復的角度來看，答案當然是沒有。如果說近代刑法的功績之一是讓刑罰脫離同害報復法則的支配，那麼保有同害報復性格的死刑，可以說難以具備（嚴格意義的）刑罰適格。關於此點將於後段詳述之。

離於社會之外的終身監禁或保安監禁有異曲同工之妙，但所帶有的道德意涵卻不相同。適用翦除處罰的類型，多為觸犯上帝誡命或社群禁忌，因此適用類型與死罪不同者在於這些行為蘊藏著本質性的邪惡。後述 Matthew H. Kramer 提出有關死刑正當化的翦除論（purgative rationale），便是從探討邪惡的本質（nature of evil）及其相對應的處置出發來證立死刑存在的一種世俗化版本。See MATTHEW H. KRAMER, THE ETHICS OF CAPITAL PUNISHMENT: A PHILOSOPHICAL INVESTIGATION OF EVIL AND ITS CONSEQUENCES 179-87 (2011).

²⁵ 參見黃榮堅（註19），頁14。

三、應報刑論的多種樣貌

應報概念承載了非常龐雜的內容，應報刑論也因為應報概念的多樣性，而呈現人言殊異的情況，誇張一點說，甚至只要不屬於預防目的的內涵都可歸入「應報」概念的範疇。一般認為，有分成被害者觀點的應報（復仇）、宗教／神的應報（天罰、因果報應）、國家道義的應報、個人贖罪觀點的應報、犯罪反作用力的應報、罪刑均衡的應報。總之，若以應報作為刑罰正當化之基礎，即可稱之為應報刑論。從近代刑法的立場出發的話，後兩者構成傳統應報論的主軸²⁶。近來則興起從規範秩序的再確認來理解刑罰的應報意義（規範的應報刑論）。

（一）傳統的應報刑論

現今一般認為，有兩種理論可解釋刑罰的正當化基礎，一是應報刑論，另一是目的刑論。應報刑論認為刑罰的意義在於對犯罪之應報，而目的刑論則認為刑罰的意義在於對犯罪之預防，包括一般預防以及特別預防²⁷。而應報刑論也有絕對應報刑論與相對應報刑論之區別。絕對應報刑論可溯及康德的絕對主義與同害報復觀以及黑格爾的刑罰等價觀點，此際刑罰本身即是目的，有罪必有罰，刑罰必須與犯罪相當。而眾所皆知，康德的絕對應報思想，對於殺人者死才是正義的展現。而黑格爾亦認為，唯有死刑，亦即剝奪殺人者的生命，才能作為殺人罪之刑罰²⁸。法乃是以理性為基礎的正義，當行為人犯罪時，則是對理性之法的「否定」亦即對正義的否

²⁶ 另見高橋則夫，刑法總論，頁495（2010年）。

²⁷ 林山田（註20），頁424以下；另參見，王皇玉，論刑罰的目的，收於：刑罰與社會規訓——台灣刑事制裁新舊思維的衝突與轉變，頁4以下（2009年）。關於目的刑論的內容不在本文的檢討範圍之內，極為詳細的參考文獻，請見小林憲太郎，刑罰に関する小講義（改），立教法学，78号，頁31-86（2010年）。

²⁸ G.W.F. Hegel 著，藤野洪、赤沢正敏訳，法の哲学I，§101，3版，頁283（2011年）。

定。基於理性之真實，法必須對犯罪予以否定，再度確認正義，以回復理性之法。此乃著名的「否定之否定（Negation der Negation）」辯證；而刑罰，即是一種正義的象徵（Symbol der Gerechtigkeit）²⁹。

相對於這種絕對主義、必罰主義的立場，相對應報刑論則認為，應報與目的不是完全互斥的概念，談及「應報」是著重過去犯罪行為之制裁，而目的則是放眼未來犯罪之防止，可以在刑罰內部統合兩種不同的刑罰目的（因此又可稱「統合理論」）。折衷了應報與預防目的的相對應報刑論幾已成為有關刑罰理論的多數見解。然而，支持相對應報論的學說仍可再細分為以應報為刑罰正當性基礎，而在應報範圍內發揮犯罪預防功能的立場（具預防機能的應報刑）³⁰，以及以預防論為基礎，但必須在罪刑均衡的範圍內始為正當之立場（應報限度內的目的刑）³¹。在結論上或許並無太大差異，但這兩種立場卻對應報的意義卻有不同的理解。以應報刑論為基調的立場（前者）肯認應報得以成為刑罰正當化之積極根據，換言之，某程度肯定作為犯罪反作用力之應報概念；而後者，則僅僅把應報理解為抑制國家刑罰權力的濫用，應報僅僅發揮維持罪刑均

29 G.W.F. Hegel 著，藤野洪、赤沢正敏訳（註28），§104，頁287-288。

30 韓忠謨，刑法原理，增訂版，頁35-36（1997年）；林山田（註20），頁423；小野清一郎，刑法講義總論，5版，頁12以下（1951年）；岡藤重光，刑法綱要總論，3版，頁468以下（1990年）。

31 黃榮堅（註19），頁17-18；平野龍一，刑法總論I，頁23（1972年）；內藤謙（註22），頁125以下。綜合評論請參見，高橋直哉，應報概念之多樣性，川端博、椎橋隆幸、甲斐克則編，立石二六先生古稀祝賀論文集，頁29以下（2010年）。另外，日本刑法學者前田雅英則將之稱為「應報型相對應報刑論」與「抑止型相對應報刑論」，然後主張前者的應報概念與重視倫理道德維持之行為反價值論的立場較為親近，而後者的應報概念則與倫理秩序之維持無直接關連，著重形式上的法的應報意義。見前田雅英，刑法總論講義，5版，頁22（2011年）。而臺灣的狀況與日本不盡相同，早期學說多半未清楚處理國家道義與倫理秩序的重視和應報概念之間的關係。明確主張刑罰應報之道義色彩者，如韓忠謨（註30），頁35。而晚近則有學說明確主張刑罰功能不在於維護社會道義或倫理，而在於保護具體的法益。參見林鈺雄，新刑法總則，3版，頁8-10（2011年）。就此，仍然肯認刑法的社會倫理維護功能之觀點者，陳子平，刑法總論，2版，頁13（2008年）。

衡的消極限定功能，亦即行為人不應該受到超過其責任程度的刑罰。因此相對應報刑論常用來說明避免預防目的過度擴張導致重罰化，有限制刑罰的作用。

然而，嚴格而論預防目的並不當然等同於重罰思想。即便是貫徹預防目的的「抑止刑論（deterrence theory）」也非一味訴諸嚴刑峻罰，一方面刑罰有其邊際遞減效果，另一方面，考慮抑止力的時候刑度的高低只是判斷因素之一，還有查獲率、定罪率以及烙印效果等因素必須考量，對於抑止刑論之支持者而言，未必需要採取重刑化的措施即可達成最佳嚇阻效果³²。因此，把預防理論和重刑思想劃上等號是學說上對於預防理論的嚴重誤解³³。

就此，嚴格而言，現今大多數的相對應報刑論者的主張，實質上已與重視預防目的之抑止刑論無太大差別³⁴。因為他們都貫徹罪刑均衡原則，並且強調刑罰的補充性，揚棄有罪必罰的絕對主義思想，同時將刑罰的正當性基礎建立在未來犯罪防止的目的上。因此，若從這種以發揮抑止效果為基調的應報刑論來思考死刑的應報意義，則就自然會導出兩個問題：1. 哪些犯罪類型在立法層次及量刑層次上運用死刑不致於輕重失衡？2. 死刑可否發揮抑止相類犯罪之效果？

首先，就後者而言，在現行法的基礎上，縱使許多實證研究皆懷疑死刑具有抑止力，但只要社會中大多數人覺得死刑雖非萬能但在特定的條件下仍有一定的抑止效果，那麼死刑就被認為是有意義的。其次，就前者而言，罪刑均衡原則的檢驗上限只有到「殺人償

32 關於最佳嚇阻效果的理論概要，see David D. Friedman & William Sjostrom, *Hanged for a Sheep: The Economics of Marginal Deterrence*, 22(2) J. LEGAL STUD. 345, 345-66 (1993).

33 黃榮堅（註19），頁17。另參考柯耀程，變動中的刑法思想，頁433以下（1999年）之說明。

34 平野龍一（註31），頁22以下參照。

命」，只要犯罪程度超過故意殺人，無論是與殺人罪之結合犯、殺害複數人、或者殺害手段凶殘、犯罪後態度不佳等情況，即使適用死刑也不會得出輕重失衡的結論，因此死刑的運用也被認為是有意義的（具正當性）。而唯有在未侵害生命法益卻仍於法定刑中列出死刑的犯罪類型，如內亂罪（刑法第101條第1項）、外患罪（刑法第103條第1項、第104條第1項、第105條第1項、第107條第1項）等，或者毒品危害防治條例（第4條第1項、第6條第1項、第15條）等，縱或可發揮一定之抑止效果，但也會因違反罪刑均衡而被認為是欠缺正當性的死刑。而在具體個案當中，針對未造成死亡結果卻仍科處死刑的案件，也可以被評價為違反罪刑均衡原則³⁵。

綜上所述，目前蔚為主流的相對應報刑論是以罪刑均衡原則作為限定刑罰範圍的手段，就死刑的運用而言，在未侵害生命法益的犯罪類型，此理論可以發揮節制死刑的一定效果。但是在現行法仍保有死刑的框架下，只要死刑之抑止效果無法徹底被否定，這個理論對於死刑制度應廢除或維持一事或許沒有置喙的餘地。

（二）贖罪的應報刑論

此種強調透過刑罰喚起犯罪行為人贖罪心理的理論，可以稱之為贖罪刑論，又由於是對過去犯行的回顧性反省，因此也可歸類在應報理論之下，本文稱之為贖罪的應報論。不過，基於刑罰以產生贖罪心理充其量只不過是一種反射作用。刑罰乃犯罪行為人被動接受之強制力，其與行為人出自內心的倫理上自我譴責用以求得倫理上的自由，終究有很大的落差；贖罪作為一種單純個人的倫理態度，不必然能透過法律喚起³⁶。至於這種贖罪觀點，也可以進一步連結到刑事矯治上的教化作用，產生特別預防效果，不過這已經脫離原初以個人贖罪作為刑罰應報意義的範疇。另一個問題是，贖罪

³⁵ 另參見王皇玉（註27），頁8。

³⁶ 林山田（註20），頁415-416。

係對被害人為之抑或對社會整體為之？若屬後者³⁷，無異是有強調對國家的道義責任之清算的色彩³⁸，而若為前者，則刑罰本身帶有與被害者和解以消除仇恨、回復和平原狀之意義。不過，無論是何者，贖罪理論都無法適切說明刑罰的質與量要到多少才足夠，以及為什麼必須要在刑罰的質以及量維持均衡才能達成責任的清算？責任清算有無替代方案？

而進一步來看死刑與贖罪之間的關係可以得知，與其說死刑本身能發揮贖罪作用，不如說在等待死刑執行的過程當中，有可能因為同樣遭遇面臨死亡的時刻，而產生倫理上的自我反省，發自內心產生對被害者之贖罪心理。除非我們設想著現世以外的、死後的世界，認為即使死刑執行，受刑人生命喪失後，其靈魂仍舊會繼續受到刑罰執行的作用產生悔悟之心，否則，贖罪心態的追求僅止於追求、等待死亡的時間點，至於生命是否真的被剝奪一事根本不重要。也因此，如溝通的應報論強調死刑的必要性，某程度便是將面臨死亡的痛苦作為手段，讓死刑犯能夠對自我的過錯產生悔悟之心，了解錯誤所在³⁹。不過問題在於，倫理上的自我負責論述，無從得知其內心究竟有無對自己的過錯產生贖罪之心。況且欲令犯罪行為人產生贖罪心理不必然非採取剝奪生命之手段不可；反之，贖罪發動之機制不但不明確，也未必與罪刑均衡的刑罰施予有直接的關聯性，因此要用贖罪或者宗教上的教化效果作為證立死刑的說法，仍有困難。

因此，若要從贖罪的觀點證立死刑，則這種脈絡下的贖罪應報論，其核心意義或許不在於追求犯罪者內在的倫理自省心態，而在於社會或被害群體透過受刑人贖罪心理所間接投射而得的撫平作

37 參見蔡墩銘，刑法總論，8版，頁309（2009年）。氏認為贖罪係對社會為之，而罪刑均衡的刑罰才能使犯罪行為人心甘情願向社會贖罪。

38 參見內藤謙（註22），頁122-123。

39 KRAMER, *supra* note 24, at 99-100.

用。也就是說，這種應報不是受刑人獨我的產物，而是社會對於「正義終告實現」的共同主觀狀態。

（三）規範的應報刑論

近年來德國刑法學界反省各種目的刑論的缺失，興起一波「應報刑論的復興」潮，而這波潮流也連帶影響到日本⁴⁰。各家學說在細部主張雖有差異，但共通的主要特徵為：反省當代追求矯治與再社會化之刑事政策目的，認為應回歸康德或黑格爾的啟蒙刑法觀，將作為刑罰正當性基礎的應報概念重新詮釋，取代過去傳統以物理性的同害報復的應報觀，而改以回復「現實法秩序之規範妥當性」為內涵，以強調刑罰的規範意義⁴¹。而從這個規範刑罰理論的基本立場出發，進一步主張刑罰的機能不在於實現抽象的正義，而是透過法秩序與規範妥當性的維持，保障法秩序下各成員之自由與自律性⁴²。其刑罰哲學上的基礎主要來自於黑格爾以及康德，從黑格爾應報刑論的兩大出發點：「作為刑罰適格的人格」以及透過否定的否定以維持「規範妥當性」而來⁴³；或借重康德的法論，基於法的

40 詳細的理論整理與解說，參見飯島暢，最近のドイツにおける規範的な応報刑論の展開，香川法学，26卷3・4号，頁331-379（2007年）。

41 有論者從規範的一般預防意義以及溝通倫理的角度認為，死刑的存在將讓法體系陷入矛盾，因此主張應廢除死刑。增田豊，死刑のパラドックス——積極的一般予防論とディスクール倫理のパーспекティヴ，ホセ・ヨンパルト（José Llompарт）、三島淑臣編，法の理論15，頁151-183（1995年）。

42 飯島暢（註40），頁337-344。臺灣學界明確採取這種主張的論者，例如：周漾沂，論「煽惑他人犯罪或違背法令」之處罰理由，臺大法學論叢，37卷4期，頁367-371（2008年）；周漾沂，論攻擊性緊急避難之定位，臺大法學論叢，41卷1期，頁422-424（2012年）。

43 如德國刑法學者 Günther Jakobs 即認為，犯罪即是行為人質疑法規範妥當性之主張，而刑罰乃是對犯罪者否定規範效力的反論（widerspruch）。可以說，基本上是依照黑格爾所主張之法的回復（die wiederherstellung des Rechts）概念而推導出來的想法。而透過刑罰的施予，能夠抵消犯罪者有責地惹起規範效力危殆化的狀態。至於後續進一步產生對一般市民的規範效力確證與熟習效果，則是屬於刑罰後的衍生物，縱使有期待其發生，但不是刑罰正當化的根據。參見玄守道，刑罰に関する一試論——ヤコブス説とバヴリーク説の比較検討を通じて，淺田和茂、石塚伸一、葛野尋之、後藤昭、福島至編，人權の刑事法

普遍原理，各人彼此尊重，相互視對方為與自己同等自由的人格體，各自間相互承認以形成共同的法關係而來⁴⁴。

規範的應報論與積極一般預防論仍有所不同。積極的一般預防論可以說是積極謀求抽象法秩序、法和平性的回復。透過刑罰的施加明確表達對犯罪行為之否定，以求對全體市民規範承認（Normanerkenntnis）之熟習（Einübung）效果，強調刑罰的社會訓育作用以回復遭受破壞之法秩序的信賴⁴⁵。可以說，由於本理論是從一般預防的角度詮釋刑罰之目的，除了將威嚇與心理強制說的字眼置換為法忠誠的訓育與規範信賴，其餘和消極一般預防理論的內容無甚差異⁴⁶。可以提出來的批評主要有三：一是這種說法反而使得刑罰的執行變得無謂，因為透過有罪判決的宣示，就可以賦予犯罪行為負面評價，再度確認法秩序，因此與其說是刑罰的目的，不如說是刑事裁判的目的及機能。其次，這種理論頂多只能證立刑罰的使用，卻無法說明，為何要採取某一種刑種以及量刑程度，刑罰科賦的正當性建立在相當貧弱且虛無飄渺的基礎上。第三，更根本的問題在於，應以刑罰手段鞏固的社會統合價值究竟應由誰決定，以及如何決定等都不明確，況且這種理論只是事後合理化國家在立法階段、司法階段乃至於執行階段當中所有施加之刑罰權力而已。

而規範的應報論則是放棄這種過於偏重一般市民共同主觀的規範熟習作用，而僅僅只是認為：犯罪是對市民間相互承認關係的破壞，同時，也是對於保障這種相互承認關係的國家法秩序規範效力

學——村井敏邦先生古稀記念論文集，頁112以下（2011年）。

44 簡單的概要整理，參見飯島暢，カント刑罰論における予防の意義と応報の限界——ヴォルフ学派のカント主義的な応報刑論に基づく一考察，香川法学，28卷2号，頁210-212（2008年）。

45 最典型的主張者為 Jakobs 早期的見解，vgl. Günther Jakobs, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2. Aufl., 1993, 1/15. 而一般對 Jakobs 規範論的理解也是從這個立場而來。

46 參見飯島暢（註40），頁334以下。

的否定，而透過剝奪行為人所擁有的與犯罪相當之自由，即可恢復被犯罪否定之法規範秩序，並且藉此使各個人自由、自律的領域得以返回原先受保障之狀態。並且，此理論將這種使自由、自律性之保障回復至犯罪前之狀態的想法，理解為規範的應報概念⁴⁷。首先，這種規範的應報概念，重新詮釋了罪刑均衡、同害報復的概念，同時也有效地從規範的層面賦予刑罰正當性的根據。其與過度重視強化市民規範意識的積極一般預防理論不同，刑罰的執行以及刑罰的程度，可以透過規範的應報概念獲得澄清。亦即，透過與犯罪相對應的自由或權利之剝奪，抵消因犯罪減損之自由或回復至犯罪前之規範秩序狀態，因此無論是刑罰的執行或刑罰的程度，都可以沿用罪刑均衡的法理來解釋。

但是這種論調其實仍舊過於偏向規範意識（無論是針對犯罪者或一般市民）的規訓，並且很容易淪為以現存的行為規範來證立制裁規範（刑罰）的正統性。規範的應報概念建立在市民之間互相承認的法關係，市民間的犯罪行為被視為是暫時脫離法的狀態，而導致互相尊重的自律狀態處於不穩定的情況，而透過刑罰制裁重新將這個不穩定的情境消除，回歸原有的秩序關係。但這種規範意義的應報論，也沒有辦法合理說明，為何必須採取刑罰手段才能回復被破壞的規範秩序，規範秩序的確認、否定與再確認一事如果無法透過其他外在標準加以檢驗，而只是一種擬制、假想出來的社會共同心理狀態，以此為基礎的刑罰制度能否通過現代法治國諸原則，例如比例原則的檢驗？這種規範應報論的立場亦忽視了刑罰作為苦痛賦予的本質，以及刑罰執行的目的、機能及任務。

這種思維隱藏了一個嚴重的問題，這個「互相承認、自由且自律的法關係」是普遍存在於所有人？抑或可能存有例外？這包括了理論上的層次以及現實上的層次。姑且不論實際上相互承認的法關

47 詳細理論，請參見飯島暢（註44），頁228-231。

係究竟能否檢證，也不論異文化之間可能根本欠缺共通價值及溝通基礎⁴⁸，規範應報概念基本上仍是立於啟蒙刑法思想的——普遍承認人的自我目的性並強調人之自律與自主性——延長線上的產物⁴⁹。但關鍵在於，這種市民形象的假設，即使在康德的法理論論述裡也確實存在著例外。亦即，那些仍處於自然狀態或前法狀態卻混雜在市民社會中的人，會持續造成（已進入法狀態下的）市民們安全保障的危殆狀態，因為這些人與服從社會契約的市民在外觀上無法區辨，以致於對市民而言會形成一種本質上的無保障性；而既然應報概念只能適用在服從社會契約之人（市民）身上，那麼對於這些混雜在市民當中的非市民，所採取的手段當然不是作為應報的刑罰，而是要求其選擇加入市民社會，或自市民社會中離去。我們千萬不能忘記，康德所謂：「即使市民社會的全體成員合意要解散社會，在解散之前所有仍在監獄中的殺人犯仍應當處死⁵⁰」這句名言，依舊建立在受刑人乃具有刑罰適格的道德主體之前提上。而對於不具刑罰適格之人（非市民），所能夠做的不是給予與罪行相均衡的應報，而是將其視為對市民社會根基的危險源，而應講求實際的隔離策略以求無害於社會。規範的應報論（以及積極的一般預防論）正隱含了上述這種「市民與非市民」的二元區分，而成為敵人刑法理論的溫床⁵¹。為了詳細說明這個問題點，以下從社會契約論

48 關於異文化在刑罰適用上的價值衝突問題，參見高山佳奈子，文化葛藤と刑罰目的論，刑法雜誌，46卷2号，頁247-257（2007年）。

49 關於近代刑法市民形象的詳細論述與批判，請見足立昌勝，近代刑法の実像，頁11-15（2000年）。

50 Immanuel Kant 著，樽井正義、池尾恭一訳，人倫の形而上学，カント全集11，法論の第1部・第49節，頁181（2002年）。

51 中文文獻，參見林立，由 Jakobs「仇敵刑法」之概念反省刑法「規範論」傳統對於抵抗國家暴力問題的侷限性——對一種導源於 Kant「法」概念先天性信念之思想的分析與批判，政大法學評論，81期，頁24-33（2004年）；日文文獻，參見櫻庭総，新たな刑法正当化戦略の問題点とその「市民」像——ヤコブスの積極的一般予防論の検討をてがかりに，九大法学，95号，頁59-65（2007年）。當然，必須澄清的是，規範的應報刑論與 Jakobs 所主張的敵人刑法理論並沒有直接的關係，甚至，採取規範應報刑論的論者多半反對或否定刑法中的

發展出來的刑罰觀來分析。

四、社會契約、應報與刑罰

（一）社會契約論出發而來的刑罰觀與死刑論

1764年，貝加利亞（Cesare Beccaria）在《犯罪與刑罰》一書當中，對死刑之正當性及必要性有相當嚴厲的質疑與批評，其主要的理由為，死刑並非以法來處死，而是國家對人民所發起的戰爭；僅有當國家處於存亡之際，剝奪犯罪人自由也無法確保統治形式之存在時，或者，當得以防止他人犯罪時，死刑才有存在的必要。但是，貝加利亞認為，這兩種理由都不能成立。

詳言之，貝加利亞先從禁止自殺的基督教教義以及社會契約論出發，認為既然人民沒有權利自殺，自然就不可能透過社會契約將剝奪自己生命的權力交給主權者，主權者不可能擁有人民本身根本欠缺的東西，因此死刑不可能是主權者的權利⁵²，死刑是一介市民和與其敵對之國民全體的戰爭；必須在有必要抹除該市民的存在，且該抹除對社會有益的情況下，死刑才具有正當性。而貝加利亞設想了兩種可能適用死刑的局面：1. 唯有當即使剝奪某市民之自由，也無法避免該市民強大的號召力與影響力，將威脅國民全體之安全，引發革命，出現秩序崩解乃至於無政府狀態之際。2. 當市民之死是唯一真能遏止他人犯罪意念的手段之際⁵³。眾所周知，這兩種情形，貝加利亞皆一一加以駁斥。

首先，在平穩的法律支配下，亦即獲國民一致支持的統治狀態

「敵人（非市民）」概念。但問題並不是那麼簡單，宣稱「非市民」不存在，並不代表在市民刑法規範的運作下「市民與非市民」的區分就自動消失。筆者想要強調的是那些無法被理論看見的「例外」究竟是如何實際影響著法體系的運作。

52 Cesare B. Beccaria 著，小谷真男譯，犯罪と刑罰，28章，頁90（2011年）。

53 Cesare B. Beccaria 著，小谷真男譯（註52），頁91。

中，沒有必要以剝奪市民的生命求取統治狀態的鞏固。其次，為了要避免他人犯罪，會帶來衝擊性影響的不是刑罰的強度，而是刑罰的長度，死刑執行只不過是一時的表演，毋寧說長期剝奪自由，令其持續痛苦才能真正帶給潛在犯罪者強力的威嚇作用⁵⁴。而終身刑所帶來的一般威嚇效果比死刑來得顯著。貝加利亞認為，死刑不但沒有實際的防止犯罪效果，同時其瞬間所展示出的血腥與殘酷超出了必要最小限度的程度，將會使得觀看（死刑）者產生憤慨與同情交織的情緒，不但不會使人變得正直，反而會讓人更堅定自己的企圖⁵⁵。以死刑告訴民眾不要殺人一事是自相矛盾、沒有道理可言的，法律既肩負著抑制人的行動之任務，就不應自己增加野蠻的手段⁵⁶。

貝加利亞當年所主張的廢除死刑理由，在現在已經成為耳熟能詳的訴求。而以不得假釋的無期徒刑（終身刑）作為死刑的替代方案一事，至今仍成為廢死運動的主要訴求之一。然而，貝加利亞自己也肯認從時間長度來看，終身刑的威嚇作用比死刑更為強大。某程度來說，終身刑甚至比死刑更為殘酷。其次，社會契約論是否必然能夠得出死刑是不正當的結論？答案也是否定的。畢竟貝加利亞仍舊是從禁止自殺的基督教教義推導出不可讓渡生命權的結論⁵⁷，只要這個前提發生變動，就會有不同的結論產生。盧梭（Jean-Jacques Rousseau）便是從社會契約論論證刑罰乃至於死刑的正當性最典型的例子。

盧梭在1762年所著《社會契約論》裡面，作如下的說明：社會契約乃以契約當事者之安全為目的，必須講求一切手段以達到此目的。而此種手段多少伴隨著危險及損害，但將不利益施加他人之上以維繫自己生命的人，在不得已的情況下，也必須要為了他人而交

54 Cesare B. Beccaria 著，小谷真男訳（註52），頁94。

55 Cesare B. Beccaria 著，小谷真男訳（註52），頁95-96。

56 Cesare B. Beccaria 著，小谷真男訳（註52），頁97。

57 如後所述，洛克也是採取相同的觀點，認為生命不可讓渡。

出自己的生命。死刑的情形也大致用同樣的觀點來觀察。正因為不想成為殺人犯的犧牲品，因此我們才會同意當自己殺了人，願意被殺。這不僅不是放棄自己的生命，相反地還是保護自己的生命免於危害的契約。締結社會契約之際，契約當事者中沒有一個人會設想到自己將來會被絞首而死⁵⁸。盧梭進一步主張，只要攻擊社會中的權利，都是對祖國的宣戰，都是叛國者，因此，與其說這些犯罪者是市民，不如說他們是敵人。透過審判及判決，才能夠證明並宣示他們違背了社會契約，不再是國家的一員。然而，對犯罪者而言，他們依舊居住在國家之內，並且自認其為國家的一員，因此，勢必要用以契約違反者之名驅逐出境，或是以公敵為名處死，以切斷其與國家間的關係。因為這種敵人，不具有法的人格（非其他國家），單單只是人類而已。因此，在這種情況下，依據戰爭之權利而將敗者殺死⁵⁹。

類似的觀點如日本學者竹田直平的「自誓死刑論」⁶⁰。該論者從社會契約論的基本假設出發，認為人類與生俱有自利行動的傾向，在欠缺有效確保自己不受他人侵害的前提下，無論何者都無法確保自己的生命、自由與幸福，然而為了要獲得他人將不侵害我的約定，勢必需先約束自己凡是他人的生命自由與幸福皆予以尊重不加以侵害，另外還要提供擔保其會遵守約定的有效方法，而互不侵犯的約定當中，最重要的是不得侵害生命，而為了要確保「不侵害生命」的約定不被破壞，勢必要找出有效且合乎正義的方法。而究竟要命違約者（殺人者）交出相當價值之物（生命），抑或命違約者交出代用物以擔保約定不被破壞？竹田教授進一步區分立法中的死刑與裁判下的死刑，認為這個問題屬於立法中死刑存廢的層次，

58 Jean-Jacques Rousseau 著，作田啓一訳，社会契約論，第2編第5章，頁55（2010年）。

59 Jean-Jacques Rousseau 著，作田啓一訳（註58），頁55-56。

60 竹田直平，立法における死刑——立法上の死刑は廃止すべきでない，甲南法学，1卷1号，頁39（1960年）。

亦即一旦在立法上全面廢除死刑，無異意味著立法者宣示殺人犯的生命價值在評價上優於被害者。此種事先給予惡人優遇的法律與近代法的精神難以調和。因此支持死刑的存在⁶¹。

而社會契約論的創始者霍布斯（Thomas Hobbes），也是從人類的自我保存本能以及對於「死亡」的恐懼，一步步推導出國家及主權者存在的正當性。眾所周知，霍布斯是從「萬人對抗萬人的鬥爭（*Bellum Omnium Contra Omnes*）」此種自然狀態的基本假設出發，人人雖然在自然狀態中皆為平等，可以透過自己的力量保全並延續自己的生命，但各人皆盡全力滿足自我保存的慾望時，自己的生命就處於隨時可能被侵害的不安定狀態。人與其他動物不同，具有理性並預測未來的能力，為了解決這種隨時處於危機的自然狀態，透過各人的自由意志，將本屬於自己之絕對的自然權讓渡一部分給國家，由國家來負責保護各成員的生命，但另一方面，各個成員必須對國家及主權者富有絕對服從的義務。重點在於，霍布斯認為，由於人都恐懼死亡，因此必然會選擇服從國家的這條路，但是這並不代表國家可以強迫其加入契約，那些不接受社會契約、不所屬於國家之人，必須自己負責保護自己的生命，因而必須對在自然狀態下面臨死亡一事有所覺悟。因此，霍布斯主張的不但是「社會契約論」，更是「生命防衛論」⁶²。

讓我們稍微將目光轉到洛克。洛克同樣採取了自然狀態以及社會契約論的假設，但與霍布斯及盧梭最大的不同是，洛克言下的「自然狀態」，並不是自我保存慾望橫行、人人必須透過己力保護生命的世界，洛克所謂之自然狀態，係指在國家成立之前，實定法尚

61 關於社會契約論可否支持死刑存在的正當性，可參閱蕭高彥（註16），頁124-130；顏厥安，毒藥與十字架，思想，17期，頁170（2011年）。

62 長尾龍一，リヴァイアサン，頁222以下（1994年）；另參見：菅原由香，ホッブズの刑法哲学，收於：変革の刑法学と犯罪の研究——ホッブズ、ケルゼン法哲学からの考察，頁219以下（2008年）。

未出現而僅存在自然法所支配之自由且平等的狀態。人人生來平等，擁有政治權力（political power），並且在自然狀態下，所有人對於其生命與所有之財產擁有絕對的權力。在自然狀態下，雖然欠缺權利保障之機制，但受自然法支配的法理依舊適用，包括人的自我保全義務，以及在他人不造成自我保全之威脅的情況下有保全他人之義務⁶³。

然而，並非每個人都嚴格遵守公正與正義的情形下，所有（property）處於令人危懼不安的狀態。固然人人都擁有處罰違反自然法之人的權限⁶⁴，不過，自然狀態下存有下列三難點：1. 公眾周知且明確的善惡判斷標準（法）並不存在。2. 欠缺客觀中立的紛爭裁決者。3. 即使有符合正義的裁決，但欠缺執行裁決的實效權力⁶⁵，而人人往往會為了自我的利益而做出偏頗的判斷。

為了避免上述困難的局面、終結這種滿溢著不安與危險的現狀，唯有將自己的政治權力託付於更能確實提供保障的政府。政府必須具備三項條件：1. 確立定著且受公認的法，可作為裁決紛爭的共通尺度、2. 公平的審判者、3. 支持、適正執行正確判決的權力，同時，政府的權力必須限定在社會成員同意託付之政治權力範圍內⁶⁶。而實定法的目的，即在於一方面保障個人之自由與平等，另一方面制約政府或國家權力的濫用。重要的是，洛克的社會契約論並不是將人的「一切」（包括生命），都託付給國家權力，毋寧說是對恣意發動的國家權力抱持警戒心，也因此，洛克雖然與其他社會契約論者一樣肯認了國家權力的優位性，但與此同時，卻也承認人民擁有抵抗國家暴力的抵抗權⁶⁷。

63 John Locke 著，角田安正訳，市民政府論，第2章第8段，頁19（2011年）。

64 John Locke 著，角田安正訳（註63），第2章第4-7、13段，頁15-20、27。

65 John Locke 著，角田安正訳（註63），第9章第123-125段，頁175-177。

66 John Locke 著，角田安正訳（註63），第9章第124-131段、第11章第135段，頁176-182、189-191。

67 參見長谷部恭男，国家の暴力、抵抗の暴力：ジョン・ロックの場合，法社会

關於刑罰權的概念，對洛克而言，觸犯自然法之人，對於他人來說是危險的存在，也是對全人類和平及安全之侵害，人人都擁有處罰違反自然法之人的權利，而處罰必須限制在剛好可阻止犯罪之程度。當一個人放棄了神所賦予全人類共通的理性，對他人施加暴力或殺害其生命時，即是對全人類的宣戰，因此，對這些罪犯可以當做像是獅子或老虎這種無法與之共同生活、無法確保安全的野獸一般，抹殺其生命。在此，洛克清楚揭示了在諸如殺害他人這種嚴重違反自然法的情況下，人人皆可殺之。洛克所要說明的是如同緊急避難或正當防衛的情境，人類去除危險源之自我防衛本能，在這些條件之下，奪去一個人的生命才是被允許（符合自然法）的⁶⁸。不過以上都是在自然狀態的情況下根本的權利。一旦形成政治社會，這種對自然法之罪的制裁權必須受到限制。就此，洛克提出了刑罰之正當性，必須建立在抑止及賠償兩大基礎之上，而刑罰必須在以「剝奪（forfeiture）」侵害者本身之所有權以填補被害者所受損害之限度內⁶⁹。

刑罰既然是以剝奪犯罪者之所有為內容，那麼刑罰的前提是該物原為犯罪者所擁有，才有可能剝奪。在此，日本學者一ノ瀬正樹從洛克的所有（property）概念，主張「死刑不可能論」，認為死刑無法成為適格的刑罰。一ノ瀬認為死刑之所以不可能成為適格的刑罰，理由有三。

第一，刑罰是以剝奪犯罪者之所有為內容。而從洛克的理論脈絡來看，對自己的生命沒有生殺與奪之權利，自然不可能透過契約

學，54卷，頁116以下（2001年）。

68 參見一ノ瀬正樹，死の所有——死刑・殺人・動物利用に向きあう哲学，頁65（2011年）。

69 John Locke 著，角田安正訳（註63），第2章第8段，頁20-21。附帶一提，所謂抑止犯罪的功能也是建立在合理賠償之上，刑罰的主要目的仍舊是剝奪所有以賠償被害。一ノ瀬正樹（註68），頁42參照。

或合意，而將自己的生命或身體交由某個絕對的權力⁷⁰。

第二，生命或身體無法作為所有、讓渡或剝奪的客體，但「人格」卻不然。在與「生命、身體」嚴格區分之下，「人格」既是所有的主體，又是所有的對象。作為自我人格展現的勞動、身體機能或能力的利用，可以作為所有的客體，自然也可以成為讓渡或剝奪的客體⁷¹。此外，「人格」需要透過意識始能確立，但「死」並無法被意識。毋寧說我們意識的是對死亡的恐懼以及等待死亡的痛苦。生命不是所有的對象，就沒有可否剝奪的問題。作為剝奪生命

70 John Locke 著，角田安正訳（註63），第4章第23段，頁42-43。需留意的是，洛克在政府論次講當中明確說國家有執行死刑的權力。一ノ瀬也清楚指出洛克本身承認國家執行死刑具有正當性。不過筆者仍須澄清，一ノ瀬所謂「死刑並不具有（洛克理論下的）刑罰適格性」，並非直接基於洛克理論的文字表述，而是基於洛克之「所有」概念及「剝奪所有」為前提下的論述。

誠如審查意見指出，是屬於非常具有特殊性以及爭議性的理論。不過，細讀政府論次講以及其他有關洛克刑罰理論的研究，除了爭論洛克究竟是死刑慎用論者抑或死刑多用論者以外，還包括洛克的刑罰一般理論究竟應屬應報、預防或者其他路線的爭執。精確來說，洛克某種程度上混雜了多種理論脈絡如應報主義與功效主義、威嚇與抑止、填補損害與預防再犯等不同理論層次的敘述，而存有詮釋的空間。惟從洛克的刑罰觀來看，死刑正當性的來源與康德所謂的「應報」不同，而是從人人皆享有的自我防衛權（以及基於自衛而擁有的執行處罰之權力），以避免危難。很清楚的，洛克的刑罰理論並不著眼於康德式的絕對應報；德國刑法學者 Ludwig v. Bar 清楚指出洛克刑罰論中的刑罰目的在於安全：以改善犯罪人（如果可能改善的話）或以死刑（若改善不可能的話）來維護安全（Sicherheit），而後者（科處死刑）與殺死獅子或老虎無異（Ludwig v. Bar, Geschichte des deutschen Strafrechts und der Strafrechtstheorien, 1882, S. 229），但問題在於死刑與其他刑罰是否共享相同的正當性基礎。

「死刑不可能論」的說法並不是指陳死刑在應然面上不應該存在，而是說，死刑不符合洛克理論中從自然狀態移轉到政治社會後應然面上的狹義刑罰概念，而死刑仍有可能在某種特殊的情狀之下，在有別於一般的刑罰脈絡下，被國家所使用；死刑的正當性基礎與其他刑罰（如自由刑、罰金刑）不同，只有在為了防免自己的生命遭受威脅，而威脅者已經放棄了神所賦予全人類共通之理性，對他人施加暴力殺害其生命時，對於這些罪犯可以當做像是獅子或老虎這種無法與之共同生活，無法確保安全的野獸一般抹殺其生命。而這是在當對方做出如殺害他人這種嚴重違反自然法的情況下，國家承繼人人所享有之自我防衛權而來的一種例外的制裁。

71 參見一ノ瀬正樹，ジョン・ロックと「所有すること」の謎，John Locke 著，宮川透訳，統治論，頁1-23（2007年）。

的死刑，並不是（狹義的）刑罰，而是以死刑為名的單純殺人行為，如同殺害眼前那威脅自己生命的獅子與老虎。

第三，死刑消除了對被害者賠償的可能性，反而違背了刑罰的意義，因此死刑不但不是刑罰，而且還是反刑罰。犯罪者被殺害之後，就喪失任何藉由勞動或其他方式向被害遺族與自己的家族乃至於社會整體來償罪⁷²。

論者最後提出了「死之所有」的弔詭之處。氏認為所謂「以死償罪」在概念上是自相矛盾的，因為這種說法是建立在人對「死之所有」，並且假設了將死讓渡後，人格（死後的人格）會繼續存在。可以說，死刑是將「（死後的）彼岸視點」導入本應立於「現世視點」的罪刑之中，因此具有與刑罰截然不同的內容⁷³。刑罰理論與刑事政策學所思考的是當下、現世，因此無論是應報論、一般預防或特別預防論乃至於消極的隔離無害化，所考慮的都是現存的個人與社會的層次，而一ノ瀨的想法正好指出了目前在東亞社會中死刑文化建立在相信因果業報與輪迴之基礎上的特殊性。

本文援引一ノ瀨的「死刑不可能論」，並不是要試圖論證洛克刑罰理論內在的矛盾，更非試圖翻轉洛克乃支持死刑之社會契約論者的這個共識。筆者所關注的重點在於：市民與非市民（放棄神所賦予全人類共通之理性、改善不可能）之區分，以及作為對應後者的死刑成為一種有別於其他刑罰的制裁手段。

（二）市民刑法的例外狀態：溝通終結、危險源隔離

以上從貝加利亞、盧梭、霍布斯、洛克的社會契約理論來觀察各自對於刑罰以及死刑正當性之看法，可以發現，近代刑法以及刑罰權的正當性建立在以社會契約論的基礎上。而儘管社會契約論的

72 一ノ瀨正樹（註68），頁61-64。

73 一ノ瀨正樹（註68），頁71。

基本前提——社會契約的締結——只是假設，但這項假設所衍生的社會制度卻隱含著市民與非市民（共同體之敵人）的二元概念區分。無論是主張刑罰謙抑、死刑廢止論的貝加利亞，支持死刑的盧梭，甚至是主張絕對主權的霍布斯皆有類似的想法：當國家統治基礎或社會根基，因為某個人或集團的行為，而產生根本性的動搖時，對於這些共同體的敵人應採取與應報刑不一樣的對應方式。即使如死刑廢止論的始祖貝加利亞也沒有徹底否定死刑在上述情境的適用可能性。更不用說盧梭等人直接將違反或破壞社會契約之人視為是共同體的敵人，不是當成公敵處死，就是驅逐出境。而康德與黑格爾的刑罰哲學，如後所述也可以見到這種二元區分的色彩。

這種「市民／非市民」對應「應報／隔離」的關係，恰巧可以呼應前面一／瀨的「死刑不可能論」的論點，亦即用刑罰對待市民，而用驅逐、隔離排害或剝奪生命的方式來對待敵人。在這個脈絡下，死刑脫離了其他刑罰正當化基礎的脈絡，而獨立生成新的概念體系。關於這點，不禁想起德國刑法學者Günther Jakobs所倡議（或「發現」）的敵人刑法（Feindstrafrecht）概念，其哲學基礎便是來自於康德、黑格爾的刑罰哲學，以及市民社會（社會契約論）的基本假設。他將刑法區分為一般犯罪者適用的市民刑法，以及適用於特殊犯罪者的敵人刑法。對於被視為敵人者，應給予不同待遇。而敵人刑法的目的不在於處罰行為人的過錯，而在於預防、隔離危險源⁷⁴。

對付共同體的敵人，需要的不再是與責任相符的應報、矯治以期再社會化的預防，而是放逐、隔離與排害措施。尼采（Friedrich W. Nietzsche）在《道德系譜學》裡提到對與社會為敵者施以刑罰

⁷⁴ 當然，孕育出敵人刑法理論的德國早已沒有死刑。在廢除死刑的國度當中，會使用其他對待危險源的方式（如保安監禁、危險犯立法等）。因此重點不在於這個理論是否跟支持或廢除死刑有關，而是在於我們是否允許例外？是否應使用有別於一般刑罰原理的手段，對待這些共同體的敵人？

的兩種意義：一是對敵人之血祭與嘲弄，亦即將刑罰視為是血祭，視為是社會成員對屈服者之侮辱與嘲弄。另一是對和平、法律、秩序或政府當局為敵者所發動之帶有宣戰或交戰意義的刑罰。這些敵人徹底威脅著共同體之存在，不遵守最根本的社會契約，因此將其視為背叛者、和平破壞者，並以與戰時相同之手段對之加以攻擊（施以刑罰）⁷⁵。需說明的是，現在一般的刑法理論皆不允許出現第一種以血祭和嘲弄為目的的刑罰⁷⁶，這個層面與其說是理論建構上的問題，不如說是一種社會心理狀態，而成為刑罰（死刑）的象徵性意義。

康德的思想，認為人作為自我目的，絕不允許只被當作工具對待。康德刑罰哲學的前提要素，即是接受法的從屬關係，進入市民社會狀態，換言之，唯有在市民的、法的狀態下，作為應報的刑罰才為可能（此際，死刑是選項之一）。在此，康德採取的是和他人比較不同的社會契約論，亦即，康德不去追問是否應締結社會契約，以及是否應因訂約就遵守該當法律，而是所有人都有脫離自然狀態（締結社會契約）、進入法狀態的義務⁷⁷。

弔詭之處在於，敵人刑法的理念，並不是在基於人的自我目的性之尊重而處罰行為人，而是以另一套邏輯，有效率地處理社會上的，無論是實在的或潛在的危險源。康德在《論永久和平》第2章的註腳當中已論及市民社會的敵之所在⁷⁸。亦即，那些仍處在自然狀態，亦即無法狀態（*statu iniusto*）下的人與已處在法狀態下的市

75 Friedrich W. Nietzsche 著，木場深定訳，道德の系譜，頁93-94（1940年）。

76 關於刑罰權的憲法與哲學上基礎，參見西原春夫，刑罰權の哲學的基礎，刑法雜誌，25卷1号，頁148以下（1982年）。

77 這是從康德《人倫形上學》的法義務區分的論述而來。Immanuel Kant 著，樽井正義、池尾恭一訳（註50），法論の第1部・第41節，頁147-149。參見長谷部恭男，カントの法理論に関する覚書，立教法学，82号，頁398-399（2011年）；中島義道，カントの法論，頁139以下（2006年）。

78 Immanuel Kant 著，遠山義孝訳，永遠平和のために，福田喜一郎ほか訳，歴史哲学論集，カント全集14，頁260-261（2000年）。

民並存的結果，就會使得持續不斷的對市民形成威脅，即便現實上並沒有產生威脅也一樣，因為對我們市民而言，這些仍處於自然狀態的人（或集團）與我們共處本身，就會讓造成安全的無保障性，因此「我可以要求他做出決斷，要不與我一同進入共同體的、法的狀態當中，或者，從我身旁消失。⁷⁹」這樣的論述也被德國刑法學家Jakobs拿來引用作為其敵人刑法概念的法哲學基礎之一⁸⁰。

讓我們再把問題焦點弄清楚一些。市民刑法預設了以下的前提：人身為理性自律的主體，彼此共同構成法的共同體，基於信賴對方具有遵法意識而經營社會共同生活，並且具有在觸犯刑罰法規時得以承擔相應責任之資格⁸¹。這種理性、自律、共生、互相尊重的市民形象，是近代刑法之所以成為可能的基本前提，也是作為應報刑成立的前提，但啟蒙時代以降所設定的市民刑法理念本身即內含著潛在的例外機制。愈強調刑法當中「基本規範共同體」的普遍性、完整性，就愈會導致出制度化的例外狀態的出現。這種市民形象的設定終究是共同主觀下所塑造出來的幻想，一旦發生殘酷且冷血的重大犯罪事件，就有可能會幻滅，而使用對抗共同體外部敵人的方式來對待這些「非市民」。我們可以說，Jakobs所提出的敵人刑法概念即是（市民）刑法的例外狀態，關鍵點便落在，如何辨識出決定敵我區分的潛在機制，以及應如何處置這些被辨識出來的「敵人（非市民）」這兩個問題上。首先，對於第一個問題，我們要問，誰設定了規範秩序？與其說是「市民」，不如說是一群受有良好教育及社會資源的、優勢種族的、主流文化的男性布爾喬亞階級。而縱使隨著時代變遷，被認為具有「市民」適格的範圍逐漸擴

79 Immanuel Kant 著，遠山義孝譯（註78），頁261。理論基礎，參見 Immanuel Kant 著，樽井正義、池尾恭一譯（註50），法論への序論・法論の区分，頁56-57。

80 Günther Jakobs 著，平山幹子譯，市民刑法と敵味方刑法，立命館法學，291号，頁1543（2003年）。

81 這種市民形象的典型論述，可參見安田拓人，刑法における人間，法律時報，80卷1号，頁48以下（2008年）。

大，但無論是隱藏下的或外顯的例外，從來就沒有消失。例如，身處異文化圈的恐怖份子不就是被當代文脈下定位為難以見容於「我們」的非市民、敵人嗎⁸²？

為了對抗這些社會共同的「敵人」，所延伸而得的處罰或制裁，包括死刑，以及以隔離無害化為目的的保安處分（如保安監禁），或者永久隔離於社會的終身刑，都是基於「非市民」的前提下，所孕育而生的產物。因此，一方面宣稱死刑作為終極的應報刑罰，另一方面認為死刑應適用在那些當罪無可逭，有永久隔離必要的「人渣」的說法，終究是自相矛盾的。需留意的是，敵人刑法理論的發祥地德國早已在戰後就廢除死刑，採取敵人刑法論或者規範應報論者也並非藉這些理論肯定或證立死刑的正當性。但這並不代表敵人刑法理論或規範應報論就與死刑制度互斥。反之，從前述說明可知，越是強調一個清晰的、法主體地位假設，就越是弔詭地勾勒出現實中的「非市民」形象。而死刑適用在這些人身上不會也無法發揮任何應報意義，而僅具有隔離以求無害於市民社會的實際效果。這就是之所以筆者認為上述兩理論與死刑具備親近關係的主要理由。

而無論是終身刑（或稱之為不得假釋的無期徒刑），其實對於社會共同體的意義與死刑並無不同，都是否定受刑人自律以求與社會成員共營共生的適格性或可能性，透過隔離的手段切斷社會成員

82 關於當代社會下的市民與敵人區分，參見 *Carlos Pérez del Valle, Zur rechtsphilosophischen Begründung des Feindstrafrechts*, in: Pawlik/Zaczyk (Hrsg.), *Festschrift für Günther Jakobs zum 70. Geburtstag am 26 Juli 2007*, 2007, S. 525-528. 論者認為，敵人刑法的概念並不是關於犯罪行為人種類的表述（行為人刑法），而是關於行為本身的敘述（行為刑法），因此只要藉由某種具體行為顯露出他想要殘留在自然狀態下之意念，自外於社會之人，就屬於敵人；例如外患（*Verrat*）、間諜活動、以及恐怖主義者所為之行為已經侵蝕了自由的根本法則，因此這些人就是敵人刑法的當然適用對象。當然，論者也進一步說明，敵人的判斷基準尚需要根據各個具體的市民社會編成內容來決定，不能一概而論，至少，就性犯罪、經濟犯罪、組織犯罪以及毒品槍枝交易的犯罪類型，相較於前述外患、間諜活動以及恐怖主義者而言尚不具備如此強烈的決定因素要以敵人來對待（前引文，頁528）。

與受刑人的溝通與連帶關係，使之永遠放逐於社會。如果我們可以理解這點，便能夠解開「以終身監禁不得假釋替代死刑」方案的迷思。因為以終身監禁作為替代死刑方案的想法，同樣維持了死刑的邏輯，其頂多只是偽善地維持著「生命神聖不可剝奪」的神主牌。縱使它可能是作為一種向民意妥協的過渡方案，但在正當性基礎的層面上，依舊有不亞於死刑的問題性存在。

當然，我們也可以從制裁效果來思考，將死刑歸類為「絕對的排除」，將終身監禁歸為「相對的排除」；死刑與不得假釋之終身監禁都具有永久隔絕於社會之共通性，但是監獄仍是「社會外的社會」，終身監禁與處死的差別在於前者仍有持續透過非常上訴、再審等救濟程序或者「赦免」⁸³以回歸社會的可能。此時似乎可以將「非市民」概念進一步劃分為絕對與相對兩種子分類，並各自對應到「死刑」與「終身監禁」兩種不同的制裁效果。這看似是不錯的區別方法，因為透過這種概念上的操作，可以進一步將死刑極度限縮到那些自始就不屬於同一社會成員的一份子，徹底欠缺社會共享價值、遵法意識的「異邦人」，而使用終身監禁制度來處理一般刑法秩序中因犯下「情節最嚴重之罪」而嗣後被視為是「非市民」之行為人，如因政社經結構所孕育而生的兇殺案等。如此一來，社會共同體內部所蘊生的犯罪，其應報最重只到終身監禁，國家不得剝奪其生命。

不過，無論是特別刑法或普通刑法，在罪刑法定的大原則底下，發動刑事制裁的契機是「行為」而非「行為人」，因此對於上述對於人的分類，勢必要透過具體的犯罪構成要件轉換成為特定的「犯罪行為」，例如人種屠殺、戰爭或發動恐怖攻擊等行為。但問題

⁸³ 判決確定但未執行的死刑犯也同樣可以經由赦免回歸社會，但法律地位與終身監禁者不同。嚴格而論，僅僅為了擔保死刑順利執行（避免死囚脫逃）就拘束其自由（羈押），等於是變相額外施加不定期的自由刑。關於死囚的法人格主體地位的問題，在此限於篇幅無法詳論。

在於辨識敵對行為與辨識敵人之間的落差。徹底撼動社會存立基礎的攻擊行為，如戰爭、恐怖活動、使用大規模毀滅性武器等行為，未必皆出自於無法共享共同體基本價值的異邦人，從共同體內部也可能蘊生出極端的敵人。日本奧姆真理教的沙林毒氣事件就是血淋淋的例子。同時，從2011年挪威大屠殺事件的主角布列唯克（Anders Behring Breivik）的人格剖析便可明瞭，即使不是「異邦人」，仍有可能做出被認為是絕對的社會公敵的行為。是以，問題根源根本不在於非市民能否再分成相對或絕對，而在於一開始設定的虛幻的「市民像」所衍生出的「市民與非市民」區分。縱使從適用對象及制裁效果來看，死刑與終身監禁固然存有差異，但問題的根源仍舊相同。

總之，規範的應報刑論基本上從社會契約論的假設出發，連結到社會普遍存在之人的自主性與自律性，並透過刑罰對於犯罪行為的否定，以求恢復犯罪前的規範秩序狀態。如果終極目標是要求犯罪行為人回歸規範秩序的行列，那麼死刑及終身監禁並無法符合規範應報論的要求。不過，這並不代表規範的應報刑論就必然能導出反對死刑存在的結論，死刑縱然不具有規範上的應報意義，但這僅意味著死刑不能適用在市民身上而已。非市民概念的析出一方面意味著市民刑法的純化，另一方面也代表對這些危險源（非市民）將會採取更有效的隔離與排除手段；死刑並沒有被這個理論排除在選項外。

五、小結

傳統的應報理論（絕對應報刑論或相對應報刑論）只能夠消極的作為限制刑罰的根據，而無法成為證立刑罰的根據。也因此，應報的意義，只剩下看似清楚但卻仍然模糊的「罪刑均衡」概念而已。而近年來應報刑論展現出新的面貌，從回顧性的處罰移轉到針對特定受刑人的展望性目的，亦即透過刑罰對於犯罪之否定以回復

規範秩序。這種規範意義的應報刑論，建立在擬制的社會共同心理狀態，並以此為基礎建構出刑罰制度的正當性。然而，「規範應報論」不談個別的、具體的犯罪預防，而是強調抽象的、一般性的「規範預期」及該預期的貫徹，以維持法系統的運作，然這種真空化式的論述，不但與現實脫節，更是一種道地的自我欺瞞，或許得以維繫刑法系統內部運作邏輯的一致性，但卻無法合理說明觸法者應承擔多少法律效果，以及這些制裁的實質意義，亦即，無法合理說明，為何施以某種處罰，以及要處罰到什麼程度，才可以「平穩」、「回復」或「抵消」了因犯罪行為所導致規範系統上的「擾動」、「破壞」或「否定評價」。換言之，其不但忽視了刑罰作為苦痛賦予的本質，亦無視於刑罰執行除了自由或權利剝奪之外還負有何等功能的問題。最重要的是，規範應報論預設了「共同承認關係」之市民形象，其蘊含著「市民／非市民」的二分，弔詭地提供了死刑或其他以保障安全、隔離危險源為目的之犯罪對應措施一個絕佳的理論溫床。

如Matthew H. Kramer所言，無論是哪一種應報刑論，其本身並不能提出徹底根除死刑的有效根據，但也無法有充分理由說明現行死刑制度有維持之必要⁸⁴。而透過死刑與應報刑論的檢討，可以發現近代以降的市民刑法「理念」無可避免會產生與敵人刑法的「現實」共生的現象。市民刑法中所謂「理性自律的主體」人類形象，可以說不過是近代刑事制度成立不可或缺的虛像。不過，解決的關鍵並不在於完全放棄這種市民形象的假想，而在於暴露出虛像背後的實像。與其反覆爭執非市民究竟存不存在，不如重新從「國家刑罰權力」與「在刑罰權力下的人」之間的關係展開討論。因為近代刑法的緣起在於對抗中世封建主義及近世絕對主義時代恣意的犯罪認定與酷苛的刑罰，要奪回人原本所擁有的自由，其出發點是對時

84 KRAMER, *supra* note 24, at 104, 115-19.

代的反省，是對國家刑罰權的不信任⁸⁵。而若要延續這種時代的批判精神至現代，勢必要揭露市民刑法及敵人刑法的共生關係，同時去思考我們應如何看待在理念之下所隱蔽的「現實」。

參、作為社會現象的死刑與責任概念

前述已揭露了近代市民刑法的「理念」及所隱蔽的「現實」，並且也確認了傳統的「應報刑論」無法對死刑存廢提供立論基礎，因為其只著重罪與罪、罪與刑之間內部的均衡性，而無法對「死罪」的當否，以及「以生命剝奪作為刑罰內容」的當否提出有效的論述。而規範的應報刑論則是回歸康德、黑格爾刑罰哲學的思考原點，從「法規範的共同承認關係」以及「法主體」的角度定位犯罪與刑罰的關係。固然在刑法論爭的洪流中，透過應報概念的再評價可以有效對抗以預防、嚇阻與抑止為中心的目的刑論，對於避免重刑化傾向、避免把人當做手段的歷史悲劇重演一事具有一定的正面意義，同時，在規範應報論的脈絡下，死刑甚至不具備刑罰適格性。

但對於社會而言，死刑的存在與使用究竟帶有什麼意義？固然，將死刑放置在近代刑法學及刑罰理論的脈絡來談存廢問題的話，結論似乎非常明確：死刑制度沒有維持的必要及正當性。但對於死刑的思考並不能僅僅止於廢死理念的片面宣揚，更不能在封閉的價值體系裡一味地繞著枯燥無味的「人權論述」迴圈裡打轉。死刑作為人類歷史中最古老的處罰方式，即使理論上並不具備（狹義的）刑罰適格，卻仍在臺灣社會當中持續發揮著深層的文化上、宗教上乃至於社會心理的作用。而探討死刑的應報意義，除了在應然

85 足立昌勝（註49），頁4。

面的法的層次上討論外，絕不能自外於「法外」的、實然面的分析。更重要的是，我們可以觀察這些法外的因素又如何回過頭影響了法體系內部的概念（如公正應報、責任）體系，同時又如何形塑了我們的死刑文化。

限於篇幅，本文只專心處理兩個問題。第一，以死刑作為「償命」、「以死謝罪」的應報，究竟是個人的？抑或是社會的？筆者打算以觀察Kramer的「翦除論」來回答這個問題。第二，在現代法治國家當中需透過最嚴格的刑事審判程序認定犯罪及刑罰，必須在符合罪刑法定原則以及責任原則之要求下，才可能出現死刑。因此，即使死刑未必具有市民刑法理念當中的刑罰適格，只要實定法中仍存在著死刑這個刑種，死刑就仍有可能出現。前已述及，以我國為例，死刑判決的出現，除了要觸犯法定刑含有死刑的犯罪類型外，必須犯罪行為人之責任到達得以判處死刑之程度。換言之，責任作為架接「犯罪論」與「刑罰論」的橋樑，不僅是有無的問題，更是程度的問題⁸⁶。問題在於，在現存的犯罪論與刑罰論的文脈中，「得以科處死刑的責任」又是如何決定的？刑法第57條所謂「科刑時應以行為人之責任為基礎」在科處死刑的場合中，其責任應如何理解？

以下，先從Kramer的翦除論來談死刑的深層意義，接下來再以作為社會現象的責任為視角，探討死刑與責任之間的關係。

一、Kramer的翦除論

關於死刑的論證基礎，Kramer提出了一項饒富深意的理論——翦除論，氏認為當有些犯罪行為具有本質性的、極端的邪惡

⁸⁶ 關於刑事責任的本質與責任原則的基本意涵，在此無法詳論，詳參：林山田，刑法通論（上），10版，頁91-93、377-381（2008年）；內藤謙，刑法講義總論（下）I，頁737-786（1991年）；山中敬一，刑法總論，2版，頁577-592（2008年）。

(monstrously evil)，足以冒瀆犯罪者的生命，同時，行為人是在該社群的控制範圍下（即使不符合共謀等要件之檢驗）犯罪時，犯罪行為人所屬的社群便有義務以死刑將犯罪者逐出社群之外，因為犯罪者持續存活就等於是對所屬社群的冒瀆。Kramer從聖經上亞干（Achan）因違反耶和華的誡命，竊取了當滅之物，以致以色列人悉數受到連累的故事，來說明所屬社群之所以必須要以執行死刑才能洗滌、淨化整個社群因邪惡所沾染的髒污⁸⁷。Kramer進一步分析了哪些行為屬於邪惡，但其也表示並非所有的邪惡行為都需處死，唯有當犯行彰顯出極端泯滅人性（a fierce repudiation of humanity），且排除一些例外的情況下，他所屬的社群便有義務透過法政系統以死刑將其生命終結，否則該社群將陷入無法抵擋的倫理困境⁸⁸。

固然Kramer反覆重申翦除論並非從宗教上論證死刑的正當性，而是一種世俗觀點的對「邪惡」及「褻瀆（defilement）」的回應，並且努力澄清翦除論僅適用於自由民主的國度，必須要符合正當、公平審判程序的前提下才能判處死刑⁸⁹，但根本的問題完全沒有解決。無論邪惡的定義再怎麼世俗化、普遍化，無論適用範圍及場域再怎麼嚴謹化，都不會改變那透過找出對社群根本規範的褻瀆者，並透過排除、犧牲褻瀆者之性命以淨化、洗滌所屬道德社群的根本思想。在此，死刑的存在更加彰顯出社會中仍存在著根深蒂固的替罪羊機制—透過劃分歸咎範圍、貼附死罪責任，找出代罪羔羊以達淨化社會平穩道德秩序的目的⁹⁰。

需澄清的是，此處所謂「替罪」，並非指死刑犯「理應」無罪或不需要負起刑事責任的意思，而是指：犯罪者的死，不僅僅意味

87 KRAMER, *supra* note 24, at 224-25.

88 *Id.* at 236-37.

89 *Id.* at 260-62.

90 參照伊藤孝夫，死刑の社会史——近世・近代日本と欧米，富谷至編，東アジアの死刑，頁257-263、288-297（2008年）。

著個人本身作為道德主體之責任的對應，還加上對應到所屬社群所課予的道義責任。令人不禁想起戰前紅極一時的道義責任論。以日本為例，最有力的支持者非小野清一郎莫屬。在他的筆下，刑罰的最終目標是維護在國家共同體當中，每一位作為倫理主體的國民的人格整全性，個人與所屬的共同體／社群之間不但緊密相連，個人之於共同體具有從屬與侍奉的關係；應報具有道義上的意義，亦即，基於人格的道義責任科處刑罰。詳言之，小野氏主張，應報觀為刑法的核心，這種應報觀不是復仇，而是人類深層的道義上的要求；而所謂刑罰，係指針對犯罪（即違反道義的行為）者負有的道義責任，所施加的法律制裁，而制裁即是國家所給予的惡害。如此意義下，應報可以說是帶有道義的、國家的色彩。不過，刑法的目的不在於應報本身，而在於透過應報維持人倫秩序、道義秩序，促進公共福祉⁹¹。這種帶有濃厚國家主義色彩的道義責任論，自然無法通過時代洪流的考驗，淪為刑法學說史的一部分⁹²。然而我們從死刑的深層意義來分析，卻可以發現即使當代的刑法秩序已極力要與國家或社群的道義秩序脫鉤，追求刑罰制度的理性化、價值中立化，然而，在保有死刑制度的國度，特別是東亞社會裡，死刑作為終極的處罰手段，仍舊帶有濃厚的道義秩序維持機能⁹³。

91 小野清一郎（註30），頁12-13。

92 詳參小野清一郎，日本法理の自覺的展開，2版，頁203-253（1942年）。學說史的介紹，見：中山研一，刑法の基本思想，增補版，頁60-64（2003年）。至今，日本學界仍有部分類似於道義責任論的見解，如有採人格責任論者，認為對於人格的非難當然帶有規範上、倫理上的意味（岡藤重光（註30），頁263），或有去除國家主義色彩，專從社會倫理的觀點建構行為人之道義責任之看法（修正的道義責任論：大塚仁，刑法概説総論，4版，頁421（2008年））。

93 關於東亞社會的死刑制度與文化背景的分析，參見藤田弘夫，東アジアと死刑の風景——死刑のイメージの比較社会学，富谷至編，東アジアの死刑，頁385-415（2008年）。而今日則多使用「規範意識の安定化」這組詞彙。例如針對日本奧姆真理教所策劃的沙林毒氣事件，控訴審判決（東京高裁平成15年5月19日公刊物未掲載・裁判所 HP）中即採取將死刑理解為「國民規範意識の安定化」為內容的觀點。

Kramer所使用的論證方式恰好反映了死刑在現代刑罰制度中的特殊位置；即使外觀上完全與其他刑罰一樣，都必須符合現代法治國家進行刑事制裁的程序與實質要件，然而正當性基礎卻與自由刑或罰金刑等刑罰手段截然不同。即使這種翦除論按其宣稱乃一種世俗觀點的論證模式，但並不改其以死刑充作受刑者對所屬社群所應負道義責任之實現，以求道德秩序平穩的本質。以近代國家的刑罰權力來追求社群道德秩序回穩的作法，在人類歷史上已經有血淋淋的教訓，其不但有淪於國家主義的問題，更有刑罰濫用的弊病。因此，當然不能認同Kramer的翦除論。但透過觀察翦除論，可以讓我們更清楚知道當代死刑所傳達的不僅僅是實際的意義（危險源隔離），更保有自古以來的象徵意義。運用國家力量剝奪人的生命，絕對不只是該個人自己的事情，更是社群、共同體整體的事。那麼，在思考死刑的應報意義時，就不能夠忽視對於社會整體而言，相應於犯罪的責任又是什麼。

二、得以科處死刑的責任

接下來讓我們回到刑法核心的理論來檢討死刑的應報意義。在近代刑法的大原則——責任原則——的指導下，「無責任即無刑罰（*nulla poena sine culpa*）」已成學說間的共識。然而，責任（或稱罪責）的內涵及犯罪論乃至於刑罰論中的意義為何，卻仍莫衷一是，未有定見。在犯罪論當中，係指個別犯罪行為的非難可能性。而這個非難的基礎一般認為建立在行為人在行為當時的「他行為可能性」⁹⁴。而在刑罰論當中，責任原則意味著責任乃刑罰的前提要件，刑法第57條所謂「科刑時應以行為人之責任為基礎」正明白宣示了此一原則。

按照絕大多數的看法，此處所謂的「責任」除了有要求罪刑均

⁹⁴ 近期有關責任論的深入檢討，參見川端博，責任の理論，頁23-81（2012年）。

衡之意義外，還帶有消極性、限定刑罰的層面，亦即：刑罰不能超越責任的範圍，責任有劃定刑罰上限的功能，但並非「有責任必有處罰」，必須根據刑罰目的、政策考量以及行為人的刑罰適應能力來劃定刑罰程度。前述「相對的應報刑論」即為此種思想的代表。這也是為什麼應報理論常被拿來作為堅持責任原則的理由⁹⁵。但光是如此還不足以說明責任作為刑罰的上限究竟應如何判斷。特別是針對在量刑階段要如何具體實踐責任原則的理念，不得不抱持懷疑的態度。日本量刑理論的專精學者同時也是前資深法官的原田國男曾云：「即使稱行為責任乃刑罰之上限，然其內容仍舊過於抽象空泛，對實際的量刑決定來說沒有什麼助益，……理念上當然應該尊重（責任主義），但實際上就作為量刑基準的角色而言可以說是次要且薄弱。⁹⁶」對於同樣繼受歐陸刑法學，且刑法的基礎構造又十分相似的我國而言，可謂同樣適用。因此，我們勢必要檢討量刑階段中責任概念的內涵，以及實際上責任（特別是得以科處死刑的責任）又是如何被形塑出來的問題。

古典的看法認為，責任非難的基礎是個別的犯罪行為，而非行為人背後的思想、性格、感情，因此又稱之為行為責任（Tatschuld）⁹⁷。由於「行為」（Tat）概念包括了狹義的行為（Handlung）以及基於行為所生之結果（Erflog），因此稱為犯行責任或犯罪行為責任比較妥適⁹⁸。無論如何，這種犯行責任的範圍包括了行為人基於意識下的行為舉止以及基於一定之因果流程下的外界變動狀態，如因犯行所生之損害或危險程度等。因此，這種犯行

95 參見林鈺雄，刑事法理論與實踐，頁286以下（2001年）。然而，應報刑論是否真能支撐責任原則，特別是罪刑均衡原理的存在，並不是沒有疑問。參見內藤謙（註22），頁122以下。

96 原田國男，量刑判断の實際，3版，頁5（2008年）。

97 參見林山田（註86），頁92-93；內藤謙（註86），頁740-742。

98 關於 Tat 與 Handlung 之間的概念區辨，涉及非常複雜的行為概念論爭，在此無法詳論。簡要的敘述可參見中山研一、淺田和茂、松宮孝明，レヴィジョン刑法3：構成要件・違法性・責任，頁15-17（2009年）。

責任帶有強調個人責任，摒除團體、連帶責任之意味，同時，唯有客觀上具體的侵害或危險才能成為責任非難之基礎，以避免讓刑罰受到群眾壓力而流於恣意。

相對於犯罪行為責任的概念，早期曾有所謂性格責任（Charakterschuld）的想法，認為行為人所帶有的對社會造成危險之性格為責任之基礎；所謂責任係指得以施加社會防衛處分之地位，這可以說是近代學派筆下的責任概念（社會責任論），是道地的行為人責任（Täterschuld）理論⁹⁹。然而需留意的是，犯罪行為是行為人反社會性格的表徵，必須出現這種犯罪表徵始能施加社會防衛措施（犯罪表徵說）¹⁰⁰。這種性格責任論的看法很快就因為人權侵害的歷史教訓而成為過去的遺物，但是從行為人之素質出發建構責任非難基礎的想法，卻持續發揮作用。德國在1940年代如Edmund Mezger所提出的素行責任（Lebensführungsschuld）、Paul Bockelmann所提出的生活決定責任（Lebensentscheidungsschuld）¹⁰¹，以及日本戰後如岡藤重光、大塚仁等人所提出的「人格責任論」為試圖解消行為責任與性格責任衝突之代表¹⁰²。

上述學說間之主張雖略有差異，然共通點為承認將行為人自我人格主體地位形成作為責任之基礎。其主要是作為提高常習犯、累犯刑度上限的理論根據，因為儘管人格或性格的形成存有諸多外在

99 責任的本質涉及到自由意志的新舊學派論爭，採取舊派立場者肯認人具有意思決定自由以及他行為可能性，因此責任之意義建立在回顧性的非難（非決定論）；而採取新派立場者，則從先天的性格以及外界環境的影響說明人沒有自由意思及他行為可能性，所謂的責任，其內涵為行為人的危險性（決定論）。然而，20世紀初期以降，論爭即有緩和跡象，而有相對的非決定論、柔軟的決定論、不可知論三種看法。詳參內藤謙（註86），頁770-786。其實只要我們跳脫本體論式的思維，從建構論的角度來觀察自由意志與責任概念，便會清楚察覺重點不是人究竟有無自由意志，而是近代刑法理念下必須透過自由意志以及他行為可能性的假設作為責任歸屬的前提。

100 內藤謙（註86），頁745-747。

101 大谷實，人格責任論の研究，頁233以下（1972年）。

102 岡藤重光（註30），頁259；大塚仁（註92），頁424。

環境與先天素質的影響與制約，然而仍然可以透過後天的努力，包括生活態度的決斷，以抗拒犯罪習性之形成。以岡藤氏的「人格責任論」為例，其主張責任作為量刑的基礎，包括了行為當時的行為責任以及至行為為止的「人格形成責任」兩個部分，行為人所帶有犯罪常習性之人格可成為特殊的刑罰加重基礎，此外就量刑時也應考慮人格形成因素以作為從重或從輕量刑之依據，例如，惡劣的生長教育環境迫使行為人陷入犯罪之境地者，得以朝向排除、減輕的量刑方向進行¹⁰³。此理論的特色在於強調行為前的人格形成過程，並且從中析出外在環境制約之外的自由形成範圍，然而，絕大多數的學說對於此說抱持懷疑與批判的態度，因為人格形成過程非常複雜，哪部分是屬於外在環境制約之影響而欠缺非難性，哪部分是屬於自由形成人格之範圍，按現今的刑事審判實務中，要作出正確的判斷幾乎不可能¹⁰⁴。

在法學論述當中，「責任」作為刑罰上限的立場雖然趨近一致，但這個責任的內涵，以及考量的範圍仍存有爭議。然而，無論採取行為責任論或人格責任論的立場，其實仍舊是以因果律來劃定「責任」的界線。因為在這種責任論的目光下，所謂責任的本質——非難可能性——除了意味著行為人有行為選擇的空間（他行為可能性），更意味著行為人的行為選擇產生了非難的契機，差別僅在於考量範圍需限定在特定行為的侵害性，抑或可擴及到「人格之形成」。主觀意思之所以扮演著決定責任有無及程度的關鍵角色，是因為自由意志的驅動下所作一連串的行為決定，進一步改變了外界狀態，產生了實質的侵害結果或撼動了共同主觀下形塑出來的法秩序，宛如水滴滴入湖面所形成的波狀擴散。換言之，近代刑法的責任觀為按照「意思→行為→損害發生→責任追究」之時間序列建構而成，然而實際上，社會中責任追索的流程卻剛好與之相

103 岡藤重光（註30），頁38、260-263、316、542。

104 福田平，全訂刑法總論，5版，頁187（2011年）。

反，而呈現「犯罪事態→無法收拾的國民感情→追究責任的集體意識→責任的特定化：因果的責任觀之作成」¹⁰⁵。也就是說，社會上透過刑罰的使用以平穩國民法感情及道德秩序，而根據處罰之需要貼付相對應的責任。因此，這種建構出來的責任與前述因果律為基礎下的責任不同，與處罰為表裡一體的概念，可以說，是因應處罰慾望所生的責任。那麼，我們又能夠如何從這個徹底翻轉視點的角度來思考「得以科處死刑之責任」呢？

前已提及，即使在刑事政策學興起，刑法與刑罰制度走向合目的化、合理化之後，在學說上努力要將刑罰機能與國民法感情作一定的區隔，死刑，與其他刑法手段不同，仍舊在特定社會當中存在著特殊的象徵意義。以因果律為基礎的近代責任概念跟因應處罰慾望的建構出的責任概念，就會在司法審判程序，特別是量刑程序中交錯匯流。量刑空間的責任概念，其實乃揉合了法理論的「責任」以及超出上述責任之外的「 α 」；這個「 α 」可能是什麼？固然會隨著社會現實而變動，但刑法意義上的「(刑事)責任」再加上「 α 」，就會轉變為一種倫理的、社會的責任，而這種責任無法透過近代的責任觀加以檢視，因而成為不能被法看見的量刑事由。

當然，我們可以簡單將這個「 α 」概稱為「社會影響因素」，然後將問題設定為刑罰與社會影響因素之間的關係¹⁰⁶。此時可以根據不同的犯罪類型設定不同的法定刑，以立法限定刑罰的上下限，以避免個案的法秩序震撼效果導致判決不符罪刑均衡的要求，或者設定量刑原則以求法官在量刑之際摒除這些無法通過量刑原則檢視的

¹⁰⁵ 參見小浜逸郎，「責任」はだれにあるのか，頁211（2005年）。另請參見，小坂井敏晶（註6），頁190以下；小坂井敏晶，人が人を裁くということ，頁162-168（2011年）。特別是小坂井氏援引社會學家 Paul Fauconnet 的責任理論（La responsabilité - étude de sociologie），重新以一社會現象的角度來理解犯罪責任。

¹⁰⁶ 參見水島和男，犯罪の社会的影響と量刑，判例タイムズ，1206号，頁28-38（2006年）。

因素。暫且先不論前者依舊可能會有「現象立法」的問題，例如近年來風起雲湧的酒醉駕車嚴罰化趨勢，其法定刑就明顯與其他相類犯罪之間的罪刑衡平關係，社會的影響因素依舊會透過針對性的刑事立法進入法體系當中。單就後者而言，其至少忽視了兩個嚴重的問題。首先，這些無法被量刑原則看見的「 α 」是否真能摒除在外？抑或會化身為犯罪行為人本身可歸責的量刑因子，如前科、常習性、反省態度等因素？或者乾脆直接將犯罪的社會影響變成一獨立的量刑因子¹⁰⁷？其次，這種處理手法也反映出對死刑判斷標準浮動化的掩耳盜鈴態度。

如果說責任是刑罰的前提，刑罰不能超越相應責任的範圍，那麼「死刑」的前提自然需要具備「得以科處死刑之責任」。然而，在我國廢除唯一死刑之犯罪後，立法者固然能劃定法定刑的範圍，但最終決定權，特別是死刑與無期徒刑之間的分水嶺決定權，僅剩下司法審判者得以擁有。換言之，「得以科處死刑的責任」的最終決定權交在法官手上。在本文開頭處已經說明了死刑量刑判斷的浮動化，一方面在判決理由中，最高法院近年來的死刑判決屢屢提及，應以行為人已經無法再回歸社會生活，無教化可能而認為有必要與社會永久隔離時才會判處死刑。然而實際上，個案情節各異，量刑審酌時所依據之責任基礎並不是單純從犯罪行為與行為人本身投射出來的平面影像，更不能化約為單純的預防目的，而是一個流動的立體空間、一個社會互動過程，揉合了複雜且多樣的影響因素。可以說，唯有這些隱性的影響因素左右了死刑的出現，根據不

¹⁰⁷ 例如，日本的死刑量刑指標裁判「永山判決」（最判昭和58年7月8日刑集37卷6号609頁）就明白地將社會影響作為一獨立的量刑因素，列入死刑的量刑判斷當中：「合併考慮犯行之罪質、動機、態樣，特別是殺害手段的偏執性與殘虐性、結果的重大性，特別是被殺害者之個數、遺屬的被害感情、社會影響、犯人年齡、前科、犯行後情狀等諸種事由之後，認為其罪責誠屬重大、無論從罪刑均衡的角度或從一般預防的角度來看，極刑乃不得已者，不得不說也得以容許死刑的選擇」。

同的個案類型也會出現不同的死刑責任的判斷空間。

由於量刑階段的責任概念匯入了法、因果律以外的價值判斷，所形成的「責任」又回過頭來回應了（傳統）應報刑論的要求，到最後所謂「應得的刑罰」乃至於「得以科處死刑的責任」在法的論述中變成是循環論證。在這種循環論證的外衣下，除非我們能反省刑罰（特別是死刑）所隱藏的秩序維持機能，否則沒有辦法有意識地撼動前述那種由處罰需求以決定責任的現狀。尤其是在當死刑的象徵意義在一個社會中被極度放大之際，死刑判決所蘊含的深層意義就更容易被彰顯出來。此際，所謂「得以科處死刑的責任」只不過是將這個死刑決斷予以事後合理化的機制而已。當然，筆者並不以喟嘆責任概念的虛妄性為滿足，這並沒有任何建設性的作用。相反地，一定程度將這個「 α 」予以可視化，將死刑判決背後所涉及的赤裸裸的價值判斷暴露出來，讓這些澄清後的現實反饋回去法的概念系統，提供新的概念反轉的契機。這也是未來極為重要的研究課題。

曾任日本東京及大阪地院法官的森炎在他2012年的新書《死刑と正義》（死刑與正義）當中，針對日本現有的死刑量刑現狀，做出極為精闢且富有啟發性的分析。他清楚地陳明，死刑判決即是在決斷不可能的情境中作出決斷，這些決斷不但緊密地與當時的社會時空背景結合，並且是徹底的價值判斷，而他的任務便是將這些無法在判決理由當中表述的價值判斷揭露出來，在曖昧不清的模糊空間當中竭盡所能的追究這些價值判斷的核心，而非單純套用量刑規則。此時，所作的死刑決斷，就會如德希達（Jacques Derrida）在《法的力量》當中所云是符合正義的決斷¹⁰⁸。固然筆者並不認同森氏關於這種死刑決斷即是符合「（暫定）正義」的結論，但其根據不同的「量刑空間」揭露其價值判斷，然後期望裁判者在煩惱困惑

108 森炎，死刑と正義，頁238-241（2012年）。

的終極之處作出決斷，而非套用人權詞彙或套用量刑規則的想法，與筆者的基本立場有異曲同工之妙，內容亦深具啟發性¹⁰⁹。臺灣的死刑量刑空間又是何等光景？死刑判決背後的價值判斷又是如何？這部份的分析仍有待後續的努力。

肆、翻轉思維方向的嘗試：修正的社會應報觀

綜上所述，強調罪刑均衡的應報刑論無法合理說明死刑存在的理由，而其他以犯罪預防為目的的刑罰理論也無法得出必然維持死刑的根據。但我們終究要面對它現實上不僅存在，而且還有極高度民意支持的事實。質言之，死刑從來就不意味著一種處於真空狀態下的，不帶有其他社會意義的「正義」。相反的，死刑制度的醞釀、誕生、變貌與消滅，都與當時社會的脈絡緊密纏繞，無法切割。在現今多元社會當中，單純僅以宗教上、道德上的理念，或許可以為個人是否支持死刑存續提供立論基礎，但卻沒有辦法從更切合社會現實的角度去為死刑之維持或廢除鞏固有力的立基點。

更重要的是，死刑存廢問題並無法從應報刑論、刑罰理論乃至於法學理論中尋求終局的解答。「死刑可否維持」與「死刑可否廢止」始終「被視為」是不同層次的問題，因此縱使我們找不到維持死刑制度存續的合理依據，這股力道並不當然能轉移到死刑廢止論的層面，讓其轉變成死刑廢止的動力。特別是，廢死運動之所以會

109 森炎（註108），頁43-223。依照他的分析，有五個主要的死刑量刑空間，加上四種變體。主要的死刑量刑空間包括：1. 市民生活之侵入與終極的犯罪被害：如著名的光市母子殺害事件，闖入家庭殺害全然無辜的婦女與小孩；2. 大量殺人與社會防衛：如地下鐵沙林毒氣事件、秋葉原無差別殺人事件；3. 永劫回歸之犯罪性向：殺人前科；4. 閉鎖空間中的重罪：如弑親；5. 金錢目的與犯罪計劃性。這些犯罪情境下的死刑決斷分別有其獨特的價值判斷。而變體的量刑空間包括：（1）不良的生長境遇、（2）異常心理、（3）少年、（4）死刑的功利主義。詳細的檢討與分析留待將來檢討。

在2010年後遇到前所未有的挫敗，除了充分反映臺灣社會對於死刑的迫切需求之外，某種意義上也反映了議論層次上這兩者的乖離；反廢死的立場，包括「殺人償命天經地義」的庶民正義觀，以及加入時間因素以求多方討好的「時期尚早論」¹¹⁰，赤裸裸肯認：死刑是否具備刑罰適格不重要，死刑究竟有無嚇阻力也不重要（嚴格而論，這與其說是實證的問題，不如說是社會心理的問題），只要對社會大眾而言死刑仍有必要存在，死刑就不能也不應廢止¹¹¹。是以，死刑的正當性與死刑的必要性被切離開來討論。縱使死刑不是嚴格意義的刑罰也無妨，死刑仍舊可以在21世紀的臺灣刑事制度中繼續存活。我們當然可以保有很多全面廢死跟全面維持現狀之間的折衷方案，其包括立法層次中，刪除不帶有生命法益侵害的死刑規定，或者向法院訴求停止量處死刑，或者向法務部要求停止執行死刑。但這些都只能算是階段性的，充其量只是圍繞在死刑核心論理

110 先肯認死刑終應廢除的立場，然後設定若干停止條件，特別像是國民情感認為現在時機尚未成熟，需等待條件成就後，如待誤判率降到最低、改善被害者的地位等條件達成之後才有廢死的餘地。在此簡單將此種論調稱之為「時期尚早論」。這種論調並不是臺灣廢死爭議中獨有的產物，以日本為例，早在明治時期開始討論死刑應否廢止時就有類似主張，當時的死刑存置論與死刑廢止論的論爭，詳見：三原憲三（註10），頁247-255、316-330。至今在日本，「時期尚早論」仍然是相當有力的見解，見：大塚仁（註92），頁521；大谷實，新版刑法講義總論，3版，頁514（2009年）。無庸置疑，一個社會制度要不要廢止，不可能一蹴可幾，需要眾多努力與調整，但誤判率永遠不可能降到容許值，被害者地位的問題也不應錯誤地拿來與廢死議題對置。「時期尚早」的說法如果隱含著永遠不會有時機成熟、條件成就的到來，那麼這種論述恰巧反映出「死刑正當性」與「死刑必要性」這兩層次的乖離。日本學者村井敏邦如是說：「所謂『時期尚早』究竟是基於何等根據而來並不明確。而且，到底何時才算是『時機』成熟，也不清楚。結果就是永遠持續著時期尚早的議論。的確，廢除死刑會產生隱約模糊的不安感。但是這個不安感永遠也不會被抹消。……勢必要在某個地方、某個時點做出決斷。」村井敏邦，刑法：現代の「犯罪と刑罰」，新版，頁14（2005年）。

111 然而，過去的歷史告訴我們，對死（及死後）的恐懼並無法換來對生命的尊重。會科處死刑的重大犯罪固然會產生人性感情上的動盪，但人性感情上的動盪應該尋求其他方法來解決，而不是透過死刑來宣洩處罰慾望。見李茂生，論刑法部分條文修正草案中保安處分相關規定，月旦法學雜誌，93期，頁104（2003年）。

的邊緣訴求¹¹²。廢死訴求者終究要面臨與應報觀正面對決的局面。

就此，筆者欲強調，死刑不是加害與被害之間的對價償還。國家代替被害者復仇的想法，在近代的刑罰制度之下來看，不但不是死刑的目的，更不是死刑的作用，充其量只能說是偶發性、反射性的效果。這個反射效果被放大後，不僅阻礙了我們對於國家刑罰體系缺失的觀察，也忽略了在近代刑法的邏輯下唯有主權者才擁有賜死（死刑）與賜生（赦免）的權力；縱使特赦權是透過裁判與法才能實現，這依舊是主權力量的展現¹¹³。自霍布斯以降，現代國家的

112 另有陳嘉銘，從四個城邦的隱喻談死刑存廢，思想，17期，頁149（2011年），從對國家機器的反省以及公民的自我醒覺著眼，來談論死刑制度的維持方案，亦即，其主張應將以「子民」為思維方式主導的死刑轉換成以「公民」為思維方式，其實踐策略包括將死刑限制在公務員或者軍人，或者要將所有涉及死刑的案子交由人民陪審議決。該文對於國家刑罰權力的反省固然相當令人贊同，然而，就該文作者所提出的兩種實踐策略，筆者卻有不同看法。就第一種策略而言，其作法仍不脫前述市民刑法「原則與例外」的二元區分思維，而第二種策略則是更加強化了死刑作為社群、共同體中道德秩序維持機制之效果。這兩種「死刑存置的配套方案」都令人難以贊同。

113 長尾龍一，「敵対刑法」論とトマス・ホッブズ，ノモス，27号，頁14-15（2010年）。從赦免權行使的歷史來看，赦免出自於封建君主的恩惠與恤刑思想，或者是宗教上，具有神職者的特殊權限（代替神施展仁慈）。而在世俗政權興起之後，即收歸成為王權的特殊力量，而當統治者手中握有的這項特殊力量，便是主權力量的展現。關於赦免權行使的歷史考察，參見菊田幸一，恩赦制度の批判的考察，法律論叢，42卷4・5・6号，頁297-304（1969年）；福田真希，フランスにおける恩赦の法制史的研究（八・完），名古屋大學法政論集，244号，頁120-129（2012年）。另可參見翟喉霞，論我國歷代刑法中恩赦制度之解析，刑事法雜誌，27卷5期，頁76-88（1983年）；翟喉霞，從刑事政策的觀點論罪之赦免，刑事法雜誌，29卷5期，頁68-97（1985年）。在刑事政策學興起之後，赦免制度也逐漸需符合目的性思考的要求，成為政策目的下為了救濟個案的不正義（如冤獄），或者達成政治利益的手段，如對政治犯、選舉犯罪之赦免。見：菊田幸一，前引文，頁335-336。

中華民國憲法第40條及赦免法具體規範了總統的赦免權限及法定程序，但赦免的實質要件卻付之闕如。換言之，赦免權雖然出自於憲法授與之權限，但赦免權的發動、種類選擇、以及發動的條件，都操之在總統身上。例如2000年底，陳水扁總統特赦了包括被外界認為冤獄的銀樓搶匪蘇炳坤、因宗教因素拒服兵役而入獄的錫安山教徒黃嘉明等19人，以及工運人士曾茂興；共通點是這些人都已窮盡法律途徑，卻被認為仍有不足以施加刑罰的餘地。特赦，堪稱以法律的形態實行法外的權力，得以創造出超出刑法秩序之外的例

構成，終極依賴於國家擁有生死權作為法權的基礎，才得以成立，要廢除死刑，等於是想要讓國家放棄這種終極的權限¹¹⁴。可以說，我們終究必須要回歸到從國家、近代政治社會的根本構造來思考，才有可能產生重新檢討死刑制度應否存續的契機¹¹⁵。

本文的目的不在於直接處理應然面的死刑存廢問題，而在於透過觀察理論與現實交錯下所形成的實像與虛像。然而，縱使沈痛地揭露了市民形象、法主體、責任、應報概念的虛幻性質，並不代表筆者即抱持棄絕一切近代刑罰制度的立場。相反地，解構後可以對現有的法概念系統重新詮釋，賦與其新的生命。

以下提出筆者對於應報概念的建構。

在死刑仍然存在的現行法之下，縱使要強調刑罰的應報意義，其應報（責任）可否全盤由犯罪者個人承擔？如果我們認知到刑罰的目的在於消極處理因犯罪所生之損害，包括修補因加害而破損的社會互動關係，那麼愈是重大的犯罪，國家愈不應該拋棄努力促使關係修補的可能性。另一方面，即便素質、環境對個人具體行動並非全盤直接發生作用，但個人的行為選擇、思考回路以及規範意識的強弱等等依舊會受到這些素質與環境因子程度不一的影響。

從前面的討論可知，我國死刑判決常以「無教化可能性」、「有再犯之虞」、「有與社會永久隔絕之必要」等作為判決死刑之積極理

外狀態，即使包裝在政策目的的外衣底下，仍舊不改其展現主權者力量的本質。因此，對應報論者來說，主權者的赦免權毋寧是對應報的侵害，如康德便主張市民與市民之間的犯罪行為不能成為赦免權行使的對象，得赦免的範圍應限縮於對君主權的侵犯（*crimen laesae maiestatis*）。Immanuel Kant 著，樽井正義、池尾恭一訳（註50），法論の第2部，第49節 E II，頁165-166。

114 引自蕭高彥（註16），頁140。

115 深富啟發性的文章：森末伸行，国家は人を殺す権利をもつか——国民国家の変容，ホセ・ヨンパルト（José Llompарт）、三島淑臣、竹下賢、長谷川晃編，法の理論30，頁165-187（2011年）。另請參見李茂生（註2），頁80-89的論述。

由，然而，死刑的特殊性在於國家透過法律直接否定了人的未來改善可能性。即使我們在某個時點對重大犯罪者下「改善不可能」的斷語，基於該判斷執行死刑的話，就永遠不可能從事後檢證到底當時的判斷是否正確。因此，死刑與其他刑罰根本上的不同在於「檢證不可能性」以及「檢證可能性的否定」¹¹⁶。

以這個視點為前提的話，令行為人負下完全責任一事，似乎有重新思考的必要。筆者認為，犯罪責任可以分成兩個層面：

- 一、經過司法系統嚴格證明程序、以相當因果關係及其他歸責理論所劃定的一次責任（直接責任），責任主體是犯罪行為人。
- 二、透過自由證明程序，從犯罪行為人生命歷程角度切入為主的二次責任（間接責任）。

前者的責任概念仍舊以「因果歸屬論」為立論前提，換言之，法的責任歸屬層次並沒有變動。然而後者（刑罰量定層次）的責任概念，必須跳脫前階段著重特定行為人的法的責任之束縛，從犯罪處理機能¹¹⁷的角度，採取相對的、交錯的責任概念。此際，責任主體並不僅包括犯罪行為人本身，尚擴及與其有關連的社群，如家庭、學校等以及其他社會網絡。在此並非要主張重回連帶責任或團體責任地思維來思考刑罰，而是將犯罪行為的形成以及成因，透過這種社會的間接責任的方式，納入量刑判斷中，成為特殊的死刑量

¹¹⁶ 曲田統，死刑制度は保持されうるか，法學新報，118卷7・8号，頁20-21（2011年）。

¹¹⁷ 吉岡一男，刑罰の犯罪処理機能，收於：刑事制度の基本概念を求めて，頁206（1984年）。在此本文乃援引前京大教授吉岡一男的見解，從有別於矯治、再社會化及隔離無害化的「刑罰」來嘗試理解現行的犯罪對應體制。吉岡主張，刑罰的機能不在於積極的犯罪預防，而在於消極的犯罪事後處理。犯罪事後處理機能並不強調法秩序回復與規範再確認的面向，甚至可謂恰好相反，要破解近代刑法的弔詭，必須放棄這種一般性的、抽象性的「秩序恢復」觀點，而要從具體的人際關係的事後修補以及對應著手。否定刑罰的預防目的，並不代表就要貫徹絕對主義的刑罰或無目的的應報刑。

刑減輕因素，並且持續性地要求福利或矯治系統投入犯罪處理與關係修補的工作¹¹⁸。這可謂相對於個人應報觀點與社會應報觀點，一種將思考軸線徹底翻轉的「（修正的）社會應報論」。

之所以使用「應報」的字眼，其意義在於著重刑罰的回顧性、事後填補性的作用，而非展望性的、事前預防的作用。但由於並非基於傳統的應報觀，而是著重「犯罪事後處理機能」，因此使用「修正的應報觀」以茲區分。至於使用「社會」一語，則是要與「個人責任（應報）」做區分，犯罪處理所應關注的不只是產生犯罪結果的近因（犯罪行為），還要關注產生犯罪行為的遠因，因此，負起犯罪事後處理責任（應報）的範圍，除了個人（加害人）之外，還需擴及到超出狹義的因果歸屬範圍外的社會整體。

換言之，在現行以因果論為基礎的責任體系下，對於「罪」的評價而言，縱使認為行為人應負起完全的刑事責任，但就「刑」的判斷，不應僅就犯罪行為及行為人之因素列入考量，更應將視野拉高到前述修正的社會應報論的層次，由社會整體負起終極的犯罪處理責任——包括持續不斷地對犯罪原因的理解¹¹⁹與犯罪者再社會化的努力，以及對犯罪受害者及其家屬的照護與救助。犯罪者之生命一旦被國家有意識的剝奪，這個終極的犯罪處理責任即無法完遂。在這種以消極事後處理為依據的刑罰理念下，罪刑均衡或合比例概念只不過是作為刑罰上限的條件，並不代表「有犯罪即有處罰」，當有其他替代刑罰的方法（轉向措施（diversion）、自由刑替代方案等）得以適切處理並修補犯罪所引起的破損時，即無需使用或減少使用刑罰。這和目前的通說見解——相對的應報論——在結論上相同，但理由則相異；相對的應報論著重以預防目的向下減輕，而

118 曲田統（註116），頁21。

119 過度仰賴以刑罰或取締等刑事制度的發動以求犯罪預防，反而會成為阻礙真正能克服或緩解犯罪原因的努力。見吉岡一男，犯罪現象の研究と刑事制度論，研修，728号，頁10（2009年）。

事後處理機能論則不看預防，只看破損的關係能否修補。而一旦在所有替代手段皆無法處理時，仍有使用刑罰的必要性及正當性，在此，刑罰作為事後處理的最後手段（刑罰謙抑性），但此時刑罰的施予仍不得超過犯罪責任的上限。由於這種回顧的應報觀融合了刑罰以及刑罰替代方案的諸種嘗試，不但與一般所理解的「應報正義」不同，也不能直接歸為「修復式正義」。關於犯罪事後處理機能論的詳細檢討，已超出本文所能處理的篇幅，僅能留待將來再行處理。

伍、結語

死刑至少有三個層面的意義：「作為應報的死刑」、「作為防免危險源的死刑」、「作為象徵的死刑」。本文檢討諸種應報刑論後認為，傳統的「應報刑論」無法對死刑存廢提供立論基礎。固然透過應報概念可以有效對抗以預防、嚇阻與抑止為中心的目的刑論，對於避免重刑化傾向、避免把人當做手段的歷史悲劇重演一事具有一定的正面意義，然而因傳統的「應報」概念只能著眼於罪與罪、罪與刑之間內部的均衡性，而無法從外部觀點對「死罪」的當否，以及「以生命剝奪作為刑罰內容」的當否提出有效的論述。而規範的應報刑論則是回歸啟蒙刑法學的思考原點，從「法規範的共同承認關係」以及「法主體」的角度定位犯罪與刑罰的關係，在此脈絡下，死刑並不能具備狹義刑罰之適格性。然而，當代刑法所依憑之市民刑法「理念」無可避免會產生與敵人刑法的「現實」共生的現象，不具備刑罰適格性的死刑即可搖身一變成為主權者對待處於例外狀態下之敵人／非市民的手段。

另一方面，在理解死刑的「應報」意義時，不可能自外於社會的角度，單純從個人的主體地位來觀察。死刑對於社會整體而言也

帶有淨化與平穩道德秩序的象徵意義；在近代刑事政策學興起後，這種象徵意義在其他刑罰手段當中雖已大幅削弱，但在高度支持死刑存置的社會中，仍有相當程度的影響力。然而，刑法與共同體的道德秩序乃至於道義觀結合的歷史悲劇仍歷歷在目，要如何擺脫這種淨化社群與平穩道德秩序機制的束縛，仍有待社會持續不斷地以批判性對話才能克服。

更深入來看，上述死刑的社會象徵意義又如何回過頭來影響著現代的刑法秩序呢？死刑的出現理應會具有「相應於死刑的責任」在支撐，也就是說，當我們在談死刑的應報意義，其實就是在談死刑與責任之間的關係。然而，若以「責任作為一種社會現象」的方式理解兩者間的關係，會發現縱使在責任原則的要求下，責任貌似成為劃定刑罰上限的具體指標，然而實際上量刑所依據之責任基礎並不是單純從犯罪行為與行為人本身投射出來的平面影像，而是一個流動的立體空間、一個社會互動過程，揉合了複雜且多樣的影響因素。可以說，這些隱性的影響因素最終左右了死刑判決的出現，而根據不同的個案類型也會出現不同的死刑責任的判斷空間。

最後，本文從修正的社會應報論觀點提供另一種擺脫死刑的思考方向。對於「罪」的評價，行為人固然應負起完全的刑事責任，但就「刑」的判斷，應考慮到的不僅是個人對犯罪的責任，同時還有社會整體的犯罪處理責任。社會整體需負起終極的犯罪處理責任，包括持續不斷地對犯罪原因的理解與犯罪者再社會化的努力，以及對犯罪受害者及其家屬的照護與救助。犯罪者之生命一旦被國家有意識的剝奪，這個終極的犯罪處理責任即無法完遂。

在多元複雜的現代社會中，或許不能期待每個社會成員都有耐心與時間傾聽彼此的聲音，但是我們或許已成熟到有信心擺脫用同害報復來換取共鳴的階段。當這個社會能夠坦誠面對死刑背後赤裸裸的價值判斷，弄清我們只不過是透過死刑排除社會共同體的邊緣

人並宣洩處罰慾望而已，同時開始反思社會對犯罪的共同責任的時候，或許才有可能在「除處死外別無他法」的思路迷宮中產生擺脫死刑制度的契機。

參考文獻

1. 中文部分

- 王兆鵬（2010），台灣死刑實證研究，月旦法學雜誌，183期，頁105-130。
- 王皇玉（2009），論刑罰的目的，收於：刑罰與社會規訓——台灣刑事制裁新舊思維的衝突與轉變，頁3-32，臺北：元照。
- （2011），死刑在台灣，台灣法學雜誌，170期，頁45-74。
- 石木欽（2011），臺灣刑事案件量處死刑之原則與趨勢（上），司法周刊，1532期，頁2-3。
- （2011），臺灣刑事案件量處死刑之原則與趨勢（下），司法周刊，1533期，頁3。
- 李茂生（2003），論刑法部分條文修正草案中保安處分相關規定，月旦法學雜誌，93期，頁101-113。
- （2011），死刑存廢論再考——分析反對廢死者的深層心理，台灣法學雜誌，169期，頁71-89。
- 周漾沂（2008），論「煽惑他人犯罪或違背法令」之處罰理由，臺大法學論叢，37卷4期，頁347-390。
- （2012），論攻擊性緊急避難之定位，臺大法學論叢，41卷1期，頁403-444。
- 林山田（2008），刑法通論（上），10版，臺北：元照。
- （2008），刑法通論（下），10版，臺北：元照。
- 林立（2004），由Jakobs「仇敵刑法」之概念反省刑法「規範論」傳統對於抵抗國家暴力問題的侷限性——對一種導源於Kant「法」概念先天性信念之思想的分析與批判，政大法學評論，81期，頁1-50。
- 林東茂（2009），刑法綜覽，6版，臺北：一品文化。

- 林鈺雄（2001），刑事法理論與實踐，臺北：新學林。
- （2011），新刑法總則，3版，臺北：元照。
- 法務部保護司編（2012），中華民國100年犯罪狀況及其分析，臺北：法務部。
- 柯耀程（1999），變動中的刑法思想，臺北：瑞興圖書。
- （2004），死刑制度對犯罪被害人的迷思，收於：刑法問題評釋，頁315-342，臺北：元照。
- 張文貞（2010），國際人權法與內國憲法的匯流：臺灣施行兩大人權公約之後，收於：社團法人臺灣法學會編，臺灣法學新課題（八），頁1-26，臺北：元照。
- 陳子平（2008），刑法總論，2版，臺北：元照。
- 陳正國（2011），死刑之不可能：一個簡單的倫理學觀點，思想，18期，頁267-277。
- 陳淑貞（2011），廢除死刑重大議題解析，全國律師，15卷8期，頁39-51。
- 陳嘉銘（2011），從四個城邦的隱喻談死刑存廢，思想，17期，頁143-149。
- 黃居正（2012），扎基告加拿大案：死刑與國際法，台灣法學雜誌，206期，頁23-30。
- 黃榮堅（2011），2010年刑事法發展回顧：慾望年代？慾望刑法？，臺大法學論叢，40卷特刊，頁1795-1841。
- （2012），基礎刑法學（上），4版，臺北：元照。
- 翟喉霞（1983），論我國歷代刑法中恩赦制度之解析，刑事法雜誌，27卷5期，頁76-88。
- （1985），從刑事政策的觀點論罪之赦免，刑事法雜誌，29卷5期，頁68-97。
- 臺灣廢除死刑推動聯盟編（2009），死刑存廢的新思維——社會安全、獄政革新、被害人保護，臺北：元照。
- 劉幸義（2011），死刑存廢爭議——反思亂世用重典——The

Controversy over the Death Penalty Reflection on Severe Penalty in Times of Disorder, 台灣法學雜誌, 169期, 頁90-92。

蔡墩銘(2009), 刑法總論, 8版, 臺北: 三民。

蕭高彥(2011), 死刑存廢: 政治思想與哲學的省思, 思想, 17期, 頁123-141。

謝世民(2011), 為廢除死刑提供一種有限的證成, 思想, 17期, 頁209-220。

韓忠謨(1997), 刑法原理, 增訂版, 臺北: 自版。

顏厥安(2011), 毒藥與十字架, 思想, 17期, 頁151-172。

蘇俊雄(1998), 刑法總論 I, 2版, 臺北: 元照。

2. 外文部分

(1) 日文

Cesare B. Beccaria著, 小谷真男訳(2011), 犯罪と刑罰, 東京: 東京大学出版会。

Friedrich W. Nietzsche著, 木場深定訳(1940), 道德の系譜, 東京: 岩波書店。

G.W.F. Hegel著, 藤野洵、赤沢正敏訳(2011), 法の哲学I, 3版, 東京: 中央公論新社。

Günther Jakobs著, 平山幹子訳(2003), 市民刑法と敵味方刑法, 立命館法學, 291号, 頁1539-1564。

Immanuel Kant著, 遠山義孝訳(2000), 永遠平和のために, 福田喜一郎ほか訳, 歴史哲学論集, カント全集14, 頁247-315, 東京: 岩波書店。

Immanuel Kant著, 樽井正義、池尾恭一訳(2002), 人倫の形而上学, カント全集11, 東京: 岩波書店。

Jean-Jacques Rousseau著, 作田啓一訳(2010), 社会契約論, 東京: 白水社。

- John Locke著，角田安正訳（2011），市民政府論，東京：光文社。
- 安田拓人（2008），刑法における人間，法律時報，80巻1号，頁45-50。
- 伊藤孝夫（2008），死刑の社会史——近世・近代日本と欧米，富谷至編，東アジアの死刑，頁257-297，京都：京都大学出版会。
- 一ノ瀬正樹（2007），ジョン・ロックと「所有すること」の謎，John Locke著，宮川透訳，統治論，頁1-23，東京：中央公論新社。
- （2011），死の所有——死刑・殺人・動物利用に向きあう哲学，東京：東京大学出版会。
- 間柴泰治（2009），死刑をめぐる論点——死刑存置論と死刑廃止論，調査と情報，651号，頁1-11。
- 菊田幸一（1969），恩赦制度の批判的考察，法律論叢，42巻4・5・6号，頁297-341。
- （1989），アメリカにおける死刑に関する司法判断と日本国憲法——いわゆる「残虐な刑罰」を中心として，法律論叢，61巻4・5号，頁125-159。
- 吉岡一男（1984），刑罰の犯罪処理機能，收於：刑事制度の基本理念を求めて，頁201-215，東京：成文堂。
- （1996），刑事学，新版，東京：青林書院。
- （1999），応報刑と謙抑主義，京都大学法学部百周年記念論文集刊行委員会編，京都大学法学部創立百周年記念論文集，第2巻，頁503-530，東京：有斐閣。
- （2009），犯罪現象の研究と刑事制度論，研修，728号，頁3-12。
- 曲田統（2011），死刑制度は保持されうるか，法学新報，118巻7・8号，頁1-32。
- 原田國男（2008），量刑判断の実際，3版，東京：立花書房。

- 玄守道(2011), 刑罰に関する一試論——ヤコブス説とパヴリーク説の比較検討を通じて, 浅田和茂、石塚伸一、葛野尋之、後藤昭、福島至編, 人権の刑事法学——村井敏邦先生古稀記念論文集, 頁111-126, 東京: 日本評論社。
- 高橋則夫(2010), 刑法総論, 東京: 成文堂。
- 高橋直哉(2010), 応報概念の多様性, 川端博、椎橋隆幸、甲斐克則編, 立石二六先生古稀祝賀論文集, 29-50頁, 東京: 成文堂。
- 高山佳奈子(2007), 文化葛藤と刑罰目的論, 刑法雑誌, 46巻2号, 頁247-257。
- (2012), 死刑制度をめぐる問題, 法律時報, 1046号, 頁36-40。
- 三原憲三(2010), 死刑廃止の研究, 6版, 東京: 成文堂。
- 山中敬一(2008), 刑法総論, 2版, 東京: 成文堂。
- 山田隆司(2012), 絞首刑と「残虐な刑罰」, 法学セミナー, 57巻1号, 頁52-53。
- 小坂井敏晶(2008), 責任という虚構, 東京: 東京大学出版会。
- (2011), 人が人を裁くということ, 東京: 岩波書店。
- 小浜逸郎(2005), 「責任」はだれにあるのか, 東京: PHP研究所。
- 小野清一郎(1942), 日本法理の自覚的展開, 2版, 東京: 有斐閣。
- (1951), 刑法講義総論, 5版, 東京: 有斐閣。
- 小林憲太郎(2010), 刑罰に関する小講義(改), 立教法学, 78号, 頁31-86。
- 森 炎(2012), 死刑と正義, 東京: 講談社。
- 森末伸行(2011), 国家は人を殺す権利をもつか——国民国家の変容, ホセ・ヨンパルト(José Llompart)、三島淑臣、竹下賢、長谷川晃編, 法の理論30, 頁165-187, 東京: 成文堂。
- 水島和男(2006), 犯罪の社会的影響と量刑, 判例タイムズ, 1206号, 頁28-41。

- 菅原由香（2008），ホッブスの刑法哲学，收於：変革の刑法学と犯罪の研究——ホッブズ、ケルゼン法哲学からの考察，頁201-222，東京：白順社。
- 西原春夫（1982），刑罰権の哲学的基礎，刑法雑誌，25巻1号，頁148-162。
- 川端博（2012），責任の理論，東京：成文堂。
- 前田雅英（2011），刑法総論講義，5版，東京：東京大学出版会。
- 増田豊（1995），死刑のパラドックス——積極的一般予防論とデイスクルス倫理のパーспекティヴ，ホセ・ヨンパルト（José Llompart）、三島淑臣編，法の理論15，頁151-183，東京：成文堂。
- 足立昌勝（2000），近代刑法の実像，東京：白順社。
- 村井敏邦（2005），刑法：現代の「犯罪と刑罰」，新版，東京：岩波書店。
- 大谷実（1972），人格責任論の研究，東京：慶応通信。
- （2009），新版刑法講義総論，3版，東京：成文堂。
- 大塚仁（2008），刑法概説総論，4版，東京：有斐閣。
- 瀧川幸辰（1951），刑法講話，東京：日本評論社。
- （1963），刑法史の断層面，東京：一粒社。
- 団藤重光（1990），刑法綱要総論，3版，東京：創文社。
- 竹田直平（1960），立法における死刑——立法上の死刑は廃止すべきでない，甲南法学，1巻1号，頁1-45。
- 中山研一（2003），刑法の基本思想，増補版，東京：成文堂。
- 中山研一、浅田和茂、松宮孝明（2009），レヴィジオン刑法3：構成要件・違法性・責任，東京：成文堂。
- 中島義道（2006），カントの法論，東京：筑摩書房。
- 長谷部恭男（2001），国家の暴力、抵抗の暴力：ジョン・ロックの場合，法社会学，54巻，頁116-129。
- （2011），カントの法理論に関する覚書，立教法学，82号，

頁384-400。

長尾龍一(1994), リヴァイアサン, 東京: 講談社。

——(2010), 「敵対刑法」論とトマス・ホッブズ, ノモス, 27号, 頁1-15。

辻本義男(1985), 死刑論争へのアプローチ, ホセ・ヨンパルト(José Llompарт)、三島淑臣編, 法の理論6, 頁165-186, 東京: 成文堂。

土本武司(2012), 絞首刑の法的根拠と残虐性, 判例時報, 2143号, 頁3-8。

藤田弘夫(2008), 東アジアと死刑の風景——死刑のイメージの比較社会学, 富谷至編, 東アジアの死刑, 頁385-415, 京都: 京都大学出版会。

内藤謙(1983), 刑法講義総論(上), 東京: 有斐閣。

——(1991), 刑法講義総論(下) I, 東京: 有斐閣。

飯島暢(2007), 最近のドイツにおける規範的な応報刑論の展開, 香川法学, 26巻3・4号, 頁331-379。

——(2008), カント刑罰論における予防の意義と応報の限界——ヴォルフ学派のカント主義的な応報刑論に基づく一考察, 香川法学, 28巻2号, 頁209-242。

福田真希(2012), フランスにおける恩赦の法制史的研究(八・完), 名古屋大学法政論集, 244号, 頁95-129。

福田平(2011), 全訂刑法総論, 5版, 東京: 有斐閣。

平野龍一(1972), 刑法総論 I, 東京: 有斐閣。

櫻庭総(2007), 新たな刑法正当化戦略の問題点とその「市民」像——ヤコブスの積極的一般予防論の検討をてがかりに, 九大法学, 95号, 頁1-91。

(2) 西文

Bar, Ludwig v. (1882), Geschichte des deutschen Strafrechts und der

Strafrechtstheorien, Berlin: Weidmannsche.

Friedman, David D., and William Sjoström. 1993. Hanged for a Sheep: The Economics of Marginal Deterrence. *Journal of Legal Studies* 22(2):345-366.

Jakobs, Günther (1993), Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2. Aufl., Berlin: W. de Gruyter.

Kramer, Matthew H. 2011. *The Ethics of Capital Punishment: A Philosophical Investigation of Evil and Its Consequences*. Oxford: Oxford University Press.

Pérez del Valle, Carlos (2007), Zur rechtsphilosophischen Begründung des Feindstrafrechts, in: Pawlik/Zaczyk (Hrsg.), Festschrift für Günther Jakobs zum 70. Geburtstag am 26 Juli 2007, Köln: C. Heymann, S. 515-528.

Revisiting the Meaning of Retribution in Death Penalty

*Yu-Wei Hsieh**

Abstract

In the opening chapter of this article, the author points out the controversy over the death penalty in Taiwan. As we know, the deterrent effect of death penalty cannot be supported by strong statistical evidence. Those who support death penalty in recent years are more likely to argue that death penalty is necessary for just desert or retribution. This trend is also called as “the renaissance of retributive theories”. However, there are too many possible meanings of “retribution” or “just desert” to clarify. In the second part of this article, the author discusses the polysemy of retribution and concludes that each of the retributive theories suffers from serious problems. In the third part, the author analyzes the meaning of “responsibility of crime” with a sociological point of view, instead of a normative one. In conclusion, it seems reasonable to realize that “just desert” or “retribution” cannot be fulfilled without taking the whole society’s responsibilities into consideration, which means the society should take responsibility to repair harms of victims and offenders, as well as the community involved. And death penalty is an obstacle to achieving this restorative purpose.

KEYWORDS: retribution, desert, social contract, state of nature, Feindstrafrecht, responsibility.

* Assistant Professor, College of Law, National Taiwan University.